IL DIRITTO NELL'ESISTENZA: linee di ontofenomenologia giuridica – SERGIO COTTA

Spiegazione del titolo e del sottotitolo.
Il titolo si rifà a quello che è il pilastro del pensiero di Cotta ovvero che il Diritto è vita, l'uomo è detentore inconsapevolmente del diritto (azioni di compravendita quotidiana), non c'è diritto senza l'Uomo, il diritto si realizza nell'esistenza umana e nella comunicazione fra gli uomini (attraverso un confronto con idee convergenti e divergenti). Soltanto dalla co-esistenza si può creare il diritto. Nella perfezione (angeli) non ci sarebbe conflitto e quindi nessun diritto. Lì dove c'è discordia Eros/thanatos c'è bisogno di diritto, nella singolarità duale (finito/infinito quindi corpo/anima) dell'Uomo c'è bisogno di diritto e l'uomo per sua natura ha bisogno di comunicare le sue idee con la relazionalità (porsi in relazione) in parità ontologica -> teoria dello specchio (vedi dopo).

Il sottotitolo vuol significare che le linee giuridiche che verranno affrontate nel corso del libro hanno a che fare con l'Essere, con l'Uomo (onto=essere -fenomenologia= studio dei fenomeni che portano alla coscienza dell'Essere). Questo diritto essendo prodotto dell'Uomo avrà caratteristiche simili all'Uomo (le norme nascono, vengono scritte e applicate, decadono, cambiano proprio come l'Uomo che è detentore del diritto è la radice prima, è *conditio sine qua non* → condizione senza la quale non si può verificare un evento.)
E' la via segnalata da S. Agostino in conformità al celebre principio del "Non andare fuori, rientra in te stesso: è nel profondo dell'Uomo che risiede la verità ", poiché senza la comprensione dell'uomo non si renderà mai piena ragione della realtà e del senso del diritto.

Cotta apre il suo libro con due premesse. Nella prima premessa Cotta esordisce ricordando il suo amico Pietro Piovani e dice che la filosofia del diritto non può essere compresa se non capiamo cos'è dapprima la filosofia.
- Filosofia significa dunque, amore per il sapere non ha un oggetto di studio come la scienza ma si occupa del tutto. Le caratteristiche della filosofia sono tre: prescrittività (che prescrive determinati comportamenti etici e morali), valutatività (esprime un giudizio di valore/disvalore), non è empirica. La Scienza invece ha tre caratteristiche opposte: Descrittività (definisce i vari fenomeni), avalutitività (non esprime giudizi di valore ma di fatto), empirica.
La filosofia si occupa dell'universale, la scienza si preoccupa di descrivere il particolare. Benedetto Croce dice che la filosofia si occupa di ciò che è vero mentre la scienza di cosa è certo. "Verum et certum convertuntur" proprio perché seppur così opposte, l'una non può fare a meno dell'altra.

Nella seconda premessa Cotta dice ai giovani di perseguire sempre la verità e di non essere uomini ma persone (carichi di dignità).

Cos'è il diritto? Quid ius? (kant)
Kant apre la sua opera "Metafisica dei Costumi" con questa domanda: "Quid ius?".
Kelsen (filosofo massimo esponente del giustpositivismo) nella sua opera "Lineamenti di dottrina pura del diritto" vuole sgombrare il campo del diritto da ogni interferenza che non sia giuridico. Egli afferma che il diritto è scritto, positivo. Il diritto non nasce con l'Uomo ma viene creato dall'Uomo.
Poi c'è il diritto naturale, quello non scritto. Il diritto naturale secondo il giustnaturalismo nasce con l'Uomo e ci sono leggi che il giurista deve solo scoprire perché queste esistono già.
Cotta risponde alla domanda sopracitata dicendo che **il diritto è un prodotto dell'Uomo** → quindi il diritto risente di tutte le caratteristiche che tipicizzano l'Uomo. Secondo Cotta l'Uomo non si può accontentare della definizione di diritto che dà Kelsen e il giustpositivismo perché è una definizione che non si occupa dei valori (Kelsen dice che il giurista si occupa solo di diritto puro, positivo non di valori). Cotta si domanda come si può descrivere il concetto di diritto/giustizia che di per sé è un concetto pregnante (pieno) di valori non scritti, basandosi solo sul diritto positivo. Kelsen rispose alle accuse con affermazioni parecchio confuse e divaganti, a dimostrazione che la sua teoria non reggeva del tutto in piedi.
Kelsen definì il concetto di giustizia un ideale irrazionale (inspiegabile) e ancora disse che la giustizia è felicità sociale (ovvero quando gli uomini sono felici di sottostare a un ordinamento giuridico, vuol dire che questo è giusto). E' pur vero che l'Uomo ha bisogno di una legislazione scritta per potersi regolare e per avere certezze nella sua vita, ma ha bisogno anche dei valori, di concetti oltre la mera oggettività positiva. Cotta dunque fa convergere l'oggettività con i valori e disvalori in un **DIRITTO NATURALE VIGENTE**

(naturalismo e positivismo). Questo diritto deve essere sì oggettivo MA deve avere in sé i diritti fondamentali dell'Uomo (diritto naturale) come il diritto ad esser libero, diritto ad un nome, alla vita ecc. Questo principio prende il nome di **Principio del Minimo Etico.**

Ma quindi Kelsen nega il valore? Assolutamente no. Però Kelsen dice che il piano giuridico e valoriale debbano essere necessariamente separati.
L'argomentazione di Sergio Cotta procede descrivendo l'Uomo come: Io – Sintetico – Razionale ovvero Unico – sintesi del finito/infinito quindi corpo/anima – l'Uomo ha bisogno di relazionarsi.

La teoria dello specchio di Cotta afferma che io devo specchiarmi nell'altro e l'altro deve specchiarsi in me al fine di raggiungere una parità ontologica, un rispetto ontologico. Quando io vedo nel prossimo un essere inferiore non ho più rispetto dell'altro e tendo a renderlo oggetto e non più Uomo. Kant diceva in uno dei suoi 3 imperativi categorici "agisci considerando il tuo prossimo come fine e mai come mezzo".
Il filo conduttore che porta a capire cos'è la filosofia del dovere giuridico è dunque da ricercare come da titolo nell'intersoggettività → ci può essere vita e dunque il diritto solo se c'è relazione tra gli uomini (mai chiudersi in se stessi).

Esistono due categorie di norme: quelle **etiche** e quelle **giuridiche**.
Quelle etiche sono caratterizzate dal: dovere – impegno – convinzioni (sento il dovere di essere corretto con il prossimo, impegnandomi con convinzione).
Quelle giuridiche sono caratterizzate da: necessità – dovere – coercizione (la norma giuridica nasce per una necessità che si viene a creare e quindi mi obbliga a comportarmi in un certo modo con la coercizione = obbligo a rispettare o sconti una pena).

Importante la differenza tra etica e morale: **l'etica mi mette in relazione con l'altro; la morale mi mette in relazione con me stesso**. Un'altra importante differenza è quella tra coercizione e costrizione: la coercizione è obbligare con la norma giuridica ad assumere un determinato comportamento e si fonda sui valori; la costrizione implica un uso della forza e si fonda sui disvalori.

Ecco un paradosso del diritto: le categorie di norme etiche e quelle giuridiche/scientifiche devono avere un comune denominatore anche se sono opposte -> **Diritto Naturale Vigente**.

CAPITOLO I: PROFILO METODOLOGICO DELLO STUDIO DEL DIRITTO

In questo capitolo Cotta ci parla di come dobbiamo approcciarci allo studio del diritto ponendoci due domande QUID IUS (cos'è il diritto) e CUR IUS (perché il diritto è proprio così) e dice che il metodo d'approccio per trovare risposte a queste domande sono due:

1. Dobbiamo avere prima un approccio basato sull'indagine descrittiva morfologica e strutturale, quella della forma perché dobbiamo capire prima come si presenta l'oggetto ai nostri occhi e successivamente passare alla parte interiore. (quid ius? Cos'è il diritto)
2. Bisogna poi compiere un'indagine teleologica del diritto, andare alle cose stesse, al fine delle cose. Vi è anche la disciplina assiologica che studia il valore delle cose. (cur ius? Perché è così)

Secondo la forma morfologica (ovvero la descrizione esterna dell'oggetto) possiamo dire che il diritto ci appare come un insieme di norme (ma non sociali o di costume ma) emanato da un'autorità legislativa organizzata e riconosciuta. **Secondo la descrizione strutturale** invece, possiamo dire che Il testo giuridico non descrive ma è un linguaggio performativo che crea e dispone con delle prescrizioni sanzionabili (direttiva in senso forte) e quindi ha una struttura deontica (dovere, necessità e si rifà alla logica dell'obbligatorietà e norma giuridica).
Secondo Kelsen la norma giuridica ha un aspetto prescrittivo sanzionatorio e la prescrizione ha per suo risvolto conseguenziale l'indicazione di una sanzione → "se è A, deve essere B"

Esistono due categorie di norme: quelle **etiche** e quelle **giuridiche**.
Quelle etiche sono caratterizzate dal: dovere – impegno – convinzioni (sento il dovere di essere corretto con il prossimo, impegnandomi con convinzione).
Quelle giuridiche sono caratterizzate da: necessità – dovere – coercizione (la norma giuridica nasce per una necessità che si viene

a creare e quindi mi obbliga a comportarmi in un certo modo con la coercizione = obbligo a rispettare o sconti una pena).
---------- differenze ----------
Il nesso di imputazione **SOLLEN** = dover essere (obbligo) → proprio perché se A deve essere B, secondo necessità giuridica.
Il nesso di causalità si configura nelle leggi naturali con il **MUSSEN**=dovere fisico, una necessità assoluta (ad esempio quelle fisiche o chimiche).
ZEIN è invece l'essere, il diritto non è un fatto, questo verbo è usato più per l'essere in natura.

Peraltro, questa struttura è comune ad ogni tipo di regola di comportamento: da quelle di etichetta a quelle mafiose, tutte hanno una struttura prescrittivo-sanzionatoria, con sanzioni di tipo diverso a seconda del genere di regola, tuttavia una norma giuridica si deve rifare al significato morfologico ovvero di norme emanate da un'autorità legislativa organizzata e riconosciuta e a quello strutturale ovvero di struttura prescrittivo sanzionatoria.

Alla luce di codesta indagine, il diritto appare quella prescrizione sanzionatoria emanata dall'autorità legislativa organizzata e riconosciuta.

Per comprendere cos'è il diritto non si può prescindere però da comprenderne il suo fine con **l'indagine teleologica**. CUR IUS? Perché il diritto proprio così e non altrimenti? Perché a seconda del fine cambia il mezzo. Dunque, individuando il fine del diritto si comprendono i mezzi. I fini del diritto sono tre:
- la protezione dell'individuo
- l'ordine interno di una comunità
- la nietzschiana volontà di potenza

Il diritto è fatto in quel modo per indurre a certi comportamenti che altrimenti sarebbero sanzionabili.

La spiegazione teleologica chiarisce perché il diritto sia fatto così, ma solo relativamente e quindi non offre ancora la ragione ultima, il perché ci sia il diritto così fatto. Per rispondere conviene porsi la domanda: PERCHE' IL DIRITTO PIUTTOSTO CHE LA SUA ASSENZA?

Perché vi è il diritto? Poteva anche non esserci? Questa domanda indaga sull'esistenza del diritto in generale, non di quello particolare determinato storicamente (es. diritto romano).
Il diritto viene visto come un fenomeno solo umano, che costituisce una modalità del vivere presente in tutto il percorso della storia umana. Attraverso il diritto si può comprendere anche l'uomo. L'indagine sull'oggetto diritto (fenomenologia del diritto) esige di essere accompagnata da una chiarificazione sull'essenza dell'uomo (risposta ontologica). Senza la comprensione dell'essere dell'uomo non si può capire la ragione dell'esistenza del diritto e il suo senso. Di fatti l'uomo crea il diritto senza accorgersene: ha il portafoglio e ignora che il possesso vale il titolo (per esempio). L'uomo è detentore del diritto, è la radice prima, è *conditio sine qua non* → condizione senza la quale non si può verificare un evento.
Essere, fare e avere è la triade che delimita la circolarità e l'evoluzione dell'uomo quindi così come l'uomo è in continua evoluzione lo sarà anche il diritto che è prodotto dell'uomo.

Quindi la presente indagine sul diritto si inscrive nel quadro della filosofia classica dell'essere, ma a partire non dall'essere in generale, **bensì dalla esplorazione dell'essere dell'ente uomo.**
È la via segnalata da S. Agostino in conformità al celebre principio del "Non andare fuori, rientra in te stesso: è nel profondo dell'Uomo che risiede la verità", poiché senza la comprensione dell'uomo non si renderà mai piena ragione della realtà e del senso del diritto.

CAPITOLO II: SENSO COMUNE E TEORIE GIURIDICHE ODIERNE.

Il mondo delle norme è diviso in due grandi pensieri il giustnaturalismo e giustpositivismo divisi su varie tematiche come il diritto e giustizia, infatti il giustnaturalismo riteneva che tra diritto e giustizia ci fosse coincidenza. Le teoria moderne non parlano di coincidenza ma di divergenza. Kelsen dice: "la giustizia non deve inquinare il diritto".

1) Giustizia e diritto.
✓il senso comune percepisce il fenomeno giuridico in termini di giustizia, la giustizia è l'essenza del diritto.
✓per le concezioni odierne, invece, diritto e giustizia appartengono a due ambiti diversi.
Il senso comune pensa che La giustizia sia l'ideale al quale deve o dovrebbe conformarsi il diritto empirico-fattuale.

Il diritto, per Kelsen invece è una creazione artificiale e viene a dipendere dalla volontà del suo autore.

QUINDI la scissione odierna trae la sua origine dal ripudio del giusnaturalismo, che metteva in comunicazione il senso comune con la scienza del diritto, assumendo una direzione (giustpositivistica) ovvero dicendo che le norme dipendono da chi le scrive e vengono create da chi le scrive, quando in realtà il senso comune sa che il legislatore può limitarsi a scoprirle, perché già presenti in natura (giusnaturalismo).

- In ambito filosofico, ne è responsabile lo STORICISMO. In questa prospettiva, perdono di significato, da un lato, i riferimenti a ogni dimensione superumana, eterna, trascendentale (e quindi fuori della storia), dall'altro ogni considerazione dei fatti naturali, i quali, accadendo secondo leggi immutabili di causalità (causa effetto) meccanica, sono privi di storia.
- In ambito scientifico, ne è responsabile il POSITIVISMO GIURIDICO, per il quale è qualificabile diritto solo quello positivo, mentre quello naturale è mera proposta di un diritto ideale.

Oltre a codeste posizioni anti-giusnaturalistiche, ha contribuito all'abbandono del modo comune e spontaneo di percepire il diritto il recente processo di trasformazione delle società avanzate; infatti l'avvento ottocentesco dell'età industriale ha determinato un innegabile processo di complessificazione della società che ha reso invece necessaria l'introduzione di norme sempre più particolari e contingenti e sempre più tecniche. Pertanto il diritto viene a presentarsi come una costruzione normativa artificiale, con la conseguenza che tanto la sua giustezza tecnica quanto la sua giustizia sostanziale risultano difficilmente percepibili dal sentire comune.

2) Obbligatorietà del diritto e origine da una volontà superiore (natura). Obbligo o volontà? Apparentemente sembrano in antitesi.
Il giustnaturalismo attribuisce obbligatorietà (e non costrizione) agli imperativi che gli appaiono conformi a giustizia e che provengono da una volontà superiore (la natura, il senso delle cose) e non umana (il legislatore) che può sbagliare. Il senso comune riconosce come norme solo obblighi giusti provenienti da volontà superiore.
Non si accettano i comandi di un bandito per esempio, perché sono costrittivi ma quelli delle norme si, perché ritenuti obbligatori. L'obbligatorietà del bandito è potere, quello delle norme è autorità.
Esso riconosce capacità di obbligare alla volontà prescrittiva allorché essa provenga non dal semplice POTERE, bensì dall'AUTORITA'.
Quindi, *Il diritto trae dunque il suo senso dalla giustizia: è obbligatorio perché è giusto e perché promana dall'autorità che, a sua volta, è emanazione della giustizia.*

**L'auctoritas è la giustizia ed ha una valenza etica (in relazione con l'altro) e durata perenne.
La potestà è un potere temporaneo, ed è contingente (è eventuale) e limitato nel tempo con valenza politica.

Per il sentire comune, dunque, il diritto non è sentito come "eteronomo" (proveniente da qualcosa di distaccato), esterno e sovrapposto alla coscienza, ma il diritto è partecipe alla coscienza poiché il diritto grazie alla sua giustizia, che rende i rapporti interpersonali stabili e duraturi "autonomo".
La regola giuridica è una proposizione linguistica (secondo Austin esiste il linguaggio ontico o dell'essere, quello deontico o del dover 'essere e il linguaggio aletico o della verità) che rispetto alla regola delinquenziale è caratterizzata da una convinzione e dall'obbligo (la norma giuridica è obbligatoria perché conforme al valore) e non dalla costrizione e dalla forza bruta (conforme al disvalore).
Importante è la distinzione tra l'avere un obbligo (soggetto attivo, sono io che mi sento obbligato ad un certo comportamento) ed essere obbligati (soggetto passivo, sono obbligato a te quindi non sono io a decidere autonomamente).

Invece, Per Kelsen la legge non viene scoperta dal legislatore perché esistente già in natura ma viene creata "la norma è frutto di un volere" e quindi Kelsen dirà che la legge è creata dall'autorità e non dalla verità e ciò è sbagliato perché non si può ridurre il diritto, frutto umano, a qualcosa di formale.

Per Cotta, le regole giuridiche sono sentite come obbligatorie quando si basano su un principio della giustificazione (appaiono conformi alla giustizia) basato sulla funzionalità coesistenziale della prescrizione (per i giustnautalisti sono giuste quelle emanate da volontà o autorità superiore). Invece, le teorie attuali come Kelsen non considerano l'obbligazione alle norme giuridiche come legati alla giustificazione ma alla validità e l'effettività: una norma è obbligatoria se valida ed è valida se inserita nell'ordinamento

3) Volontarismo e Ragione
Il giustnaturalismo è convinto che ci sia la ratio, la ragione a governare il mondo e che quindi tutte le leggi siano già presenti in natura ed è compito del legislatore solo scoprirle e trascriverle.
Le teorie moderne invece attribuiscono un volontarismo alla stesura delle leggi, dicendo che sono frutto della volontà di un legislatore.

Un'analisi storica sarebbe in grado di collocare il sorgere di codesta scienza entro il quadro complesso di vari mutamenti verificatisi nell'età moderna. In linea generale, quel periodo storico è contraddistinto dall'affermarsi in un primo tempo di una supremazia della legislazione statale sulle altre fonti tradizionali del diritto; in un secondo tempo, a partire dal costituirsi dello Stato nazionale sovrano, si può parlare di un vero e proprio monopolio statale del diritto.

Sul piano filosofico è emblematica al riguardo la ben nota costruzione hegeliana, delineata nei "Lineamenti di filosofia del diritto". In essa, "il diritto (interpersonale) è tolto dalla sua astrattezza e il diritto (sociale) della famiglia e della società civile sono tolti dalla loro eticità parziale allorché vengono assunti nella suprema e globale eticità dello Stato. Solo nello Stato viene raggiunta la REAL-RAZIONALITA' della legge nella sua "universalità (razionale) e determinatezza (reale)".
La teoria hegeliana costituisce l'esempio più coerente della riduzione del diritto al diritto statale, già enunciata da Fichte e poi proseguita dagli idealisti fino, in Italia, a Giovanni Gentile.

La scienza giuridica contemporanea si è divisa in 2 tipi:

1) CHI INDAGA SUL QUID IURIS KANTIANO (cos'è statuito da un ordinamento) Che ha per proprio ambito di indagine un dato ordinamento giuridico positivo e vari contenuti normativi per assicurare la certezza del diritto.
2) CHI INDAGA SUL QUID IUS KANTIANO (cos'è il diritto) Che si rifà al diritto positivo, ma allo scopo di ricavarne quei concetti che permettono di determinare in generale la giuridicità dei più vari ordinamenti giuridici.

Nonostante le apparenze, le principali teorie giuridiche odierne sono accomunate di fondo dal VOLONTARISMO. Si consideri in primo luogo il FORMALISMO della "dottrina pura del diritto di Kelsen", che sembra assai estraneo al volontarismo. In questa prospettiva, la validità delle norme vien fatta coincidere con la loro esistenza giuridica ed è ritenuta sufficiente a stabilirne l'obbligatorietà.
Ma proprio la nozione di norma fondamentale ha dato adito a seri dubbi sulla consistenza di tale formalismo. Nella realtà essa non può che emanare che da un atto di volontà; ogni dubbio è dissolto da Kelsen nella "teoria generale delle norme", dove la norma è esplicitamente asserita come "il senso di un volere, di un atto di volontà". Il volontarismo non potrebbe essere maggiore.
Si consideri ora la teoria istituzionalistica del diritto, per il quale la societas è identificata con il corpo sociale organizzato, secondo la nota tesi di Santi Romano; ma l'organizzazione non si produce da sola bensì mediante norme organizzative che hanno un autore, alla cui volontà si fa implicito riferimento.
Infine, il volontarismo è il supporto evidente delle teorie giuridiche "neo-contrattualistiche": in queste, il contratto non è assunto quale fatto storico bensì quale figura simbolico-metaforica, pur tuttavia esplicativa del fondamento dell'ordinamento giuridico, poiché il contratto esprime quell'accordo di volontà tra i contraenti, che è normativo per essi.

Quindi per il giustpositivismo la volontà e la potenza sono frutto della volontà superiore del legislatore che ritenuta capace di instaurare il diritto, impone obblighi in modo eteronomo (dall'alto) senza dover ricorrere alla sua giustizia. Questo però è un paradosso dal momento che estromette dalla leggi tutte quelle regole che non provengono dal legislatore tuttavia sono obbligatorie (non uccidere è difficile non pensarla a prescindere dell'ordinamento) e inoltre rende leggi anche leggi non giuste (vedi leggi raziali contro diritti dell'uomo).

PARTE II → Genesi ontoesistenziale della giuridicità

La seconda parte parla della nascita del diritto nella coscienza umana.
Il diritto come sorge nella coscienza? Il diritto nasce per garantirmi nell'intersoggettività che non ci sia l'homo hominis lupus. Una massima di Vico riassume al meglio l'evoluzione antropologica dell'uomo dicendo che: "L'uomo prima SENTE senza avvertire, poi in una fase evolutiva AVVERTE con animo perturbato e commosso e infine GIUDICA con mente pura e sgombra" G. Vico

CAPITOLO III: IL SORGERE DEL DIRITTO NELLA COSCIENZA.

Esistono 2 CONCEZIONI riguardo il modo in cui il diritto "nasce" (genesi ontoesistenziale della giuridicità):

- la concezione AUTONOMA: sostiene che il diritto nasce all'interno dell'essere umano, nella sua coscienza e natura: quindi il diritto risulta qualcosa di libero, in quanto nasce dal libero sentimento dell'essere umano; *(diritto autonomo = diritto-pretesa)*
- la concezione ETERONOMA: sostiene invece che il diritto provenga dall'esterno dell'essere umano, quindi non dalla libera attività personale: esso è qualcosa di imposto che l'individuo sente come estraneo e nei confronti del quale, perciò, egli risulta insofferente. (*diritto eteronomo = diritto-regola).*

E' chiaro che questa seconda teoria è ostile al diritto e quindi si basa su un sostanziale "antigiuridismo": il diritto viene visto come una serie costrittiva di obblighi e divieti, imposto con la minaccia di pene e sanzioni di tipo costrittivo-repressivo, quindi privo di ogni autenticità umana.

L'homo iuridicus NON DEVE ESSERE "maschera" dell'uomo autentico, bensì specchio dell'uomo integrale con i suoi diritti, valori, doveri e il diritto eteronomo ovvero il "diritto-regola", si basa su una serie artificiosa di norme e regole che non rappresenta a pieno l'uomo;
Il diritto autonomo è invece il "diritto-pretesa", che si basa su tutto ciò che l'individuo crede di avere ragione di pretendere, senza essere ostacolato da nessuno né da alcuna regola.

In realtà, questi due diritti non si escludono a vicenda, ma possono e devono sussistere insieme SOCIONOMIA (vedi alla fine): non vi è diritto-regola che non faccia sorgere in altri un corrispondente diritto-pretesa e viceversa; "regola" e "pretesa", ovverosia "repressione" e "garanzia" sono interdipendenti e collegate fra loro.

Insomma **il diritto** viene visto come una sorta di Giano bifronte, con una faccia minacciosa (diritto-regola) e una faccia benigna (diritto-pretesa). Infatti nelle lingue europee il sostantivo "giurisprudenza" e l'aggettivo giuridico derivano dal latino jus che significa jungere=congiungere. Anche il termine "diritto", trae la sua origine dal tardolatino "dirictum" =corretto, affidabile; in polacco diritto ha la stessa radice di verità.
E' questa la prova che tra diritto ed esistenza non vi è grande eterogeneità: il diritto si basa su una sorta di autenticità esistenziale, cioè non è qualcosa di astratto ma esiste in maniera autentica.

2) Assicuriamoci ora se veramente sia possibile sostenere che il diritto esiste veramente, cioè ne verifichiamo l'autenticità sostanziale; in altri termini, verifichiamo l'autenticità di quel modo di vivere che viene denominato "giuridico".
Cosa significa "vivere giuridico"? Possiamo dire che significa "vivere secondo principi e regole oggettive

e vincolanti", cioè "vivere secondo giuridicità".

Partiamo dall'esame dell'individuo al di fuori dei rapporti con gli altri individui: ricordiamo che la teoria detta del "giusnaturalismo" sostiene l'esistenza di uno stato di natura originario dell'individuo che vive da solo, al di fuori di una società; questa teoria è oramai superata, in quanto giudicata troppo semplicistica ed è stata sostituita da un tipo di giusnaturalismo moderno, che pure prevede uno stato di natura per l'individuo ma in modo diverso: il vecchio stato di natura si basava sull'assenza di ogni regola e quindi immaginava un sistema di continue lotte fra gli individui, mentre il nuovo stato di natura vede come condizione naturale dell'uomo quella in cui ogni individuo è libero di auto-realizzarsi secondo la propria volontà, libera da "pastoie", una delle quali è proprio il diritto. Il punto comune di queste 2 teorie è che comunque l'individuo è estraneo al diritto e non ne sente la necessità, ossia l'anti-giuridismo.

L'individuo è quindi visto come un'entità a sé stante, inquadrato secondo una concezione di ASEITA' (da se, per se). Ma ciò è veramente possibile?
Se fosse possibile, noi avremmo un individuo "astratto", che starebbe al di fuori dalla realtà concreta dell'esistenza, che è caratterizzata dalle relazioni col mondo esterno e gli altri uomini.
Vico riassume al meglio l'evoluzione antropologica dell'uomo dicendo che: "L'uomo prima SENTE senza avvertire, poi in una fase evolutiva AVVERTE con animo perturbato e commosso e infine GIUDICA con mente pura e sgombra" (l'uomo si accorge di sè, si accorge degli altri, si relaziona e crea il diritto).
Come detto, l'uomo non è un'entità astratta ma ben concreta, che si manifesta nel mondo esterno, "si fa presente nel mondo" mediante le sue azioni.
L'azione dell'uomo è frutto della sua mente ed è decisa dalla sua VOLONTA', sicché non vi è nulla di più individuale dell'azione, decisa e voluta dall'uomo, dal suo "io".
L'uomo perciò vuole, ma COSA VUOLE? Innanzitutto vuole FARE, cioè vuole agire ed estrinsecarsi all'esterno; ma non basta, egli vuole anche AVERE (beni materiali, ma anche gioia, felicità, successo nelle cose che fa, ecc.). Questo voler fare e voler avere si sommano a loro volta nella volontà di ESSERE; ciò accade in quanto l'individuo, sommando il fare e l'avere, si rende conto di esistere, quindi di essere.

L'azione dell'uomo non è qualcosa di compatto, ma è la somma di 3 momenti che sono fare-avere-essere: dall'essere si procede al fare e all'avere dando così origine all'essere ontico.

Si tratta per il momento di un essere "empirico", cioè un essere che esiste in concreto ma che non ha ancora una sua spiritualità: un ESSERE ONTICO, non ancora metafisico. Diverrà qualcosa di metafisico con l'autocoscienza dell'io e degli altri giungendo ad una socionomia.

Come si fa a conciliare la sintesi fare-essere-avere, che presuppone la libertà, con il mondo delle regole oggettive e vincolanti?
Il soggetto è un ente dinamico portato ad agire continuamente per raggiungere ciò che vuole, ma si accorge ben presto che il suo agire non è libero in quanto incontra sempre una realtà esterna che non gli appartiene e gli è estranea. È quindi il "mondo dell'ALTERITÀ": costituito da esseri che agiscono "non come me", ma "come me". L'uomo deve perciò rendersi conto di non agire nel vuoto umano, ma in un mondo in cui ci sono altri "io", così si rende conto che come l'uomo pretende qualcosa allora "pretende da altri di non essere ostacolato" sicché anche gli altri soggetti hanno delle pretese che per loro sono vere e giuste, e ne deriva anche la compresenza di pretese. → Fondamentale concetto da cui nasce il diritto.
Come si risolve la questione? Con la guerra di tutti contro tutti? Il bellum omnium contra omnes?
Con il processo di autocoscienza dell'io. Procediamo per FASI PROGRESSIVE:

A) L'altro è pari all' io nella capacità (entrambi sono capaci) di pretendere per sè secondo la propria verità.
L'io deve rendersi conto che se è giusto sentire-pretendere per sé, è altrettanto giusto che l'altro, senta-pretenda in quanto anch'esso è pur sempre un io. Il riconoscimento deve essere reciproco e se l'io perviene a questo riconoscimento di reciprocità, si rende conto che è possibile un'alternativa più accettabile alla guerra contro tutti: nel momento in cui si ammette il riconoscimento dell'altro, si ammette la compossibilità delle pretese, cioè si ammette che le varie pretese dei vari io possono coesistere.

Quindi la compresenza delle pretese può ammettere la loro compossibilità? Vi sono 3 ipotesi:
non interferenza: nessun problema perché le due pretese non si scontrano fra loro in quanto su piano diversi;

- convergenza: l'io deve rendersi conto che deve abbandonare la tesi per cui solo la propria pretesa sia vera e perciò legittima; deve dunque lasciar perdere l'atteggiamento imperativo "voglio, dammi, lasciami fare" e sforzarsi di comunicare con l'altro per rendere le rispettive pretese compatibili.
- opposizione:

B) L'altro è pari all'io nella capacità di intendere la pretesa
L'io si è reso conto che non può più "agire per sé" ma deve entrare nel piano della comunicazione intersoggettiva e tentare un'opera di convincimento dell'altro, il quale è capace di intendere la sua pretesa, allo scopo di trovare una verifica e una verità comune, che l'altro è in condizione di capire.

C) L'altro è pari all'io nella capacità di intendere una verità comune
A questo punto il notevole passo in avanti che è stato compiuto: le due posizioni diventano convergenti accettando le reciproche pretese. Ciascuna delle parti mira pur sempre al proprio utile, ma si rende conto anche che per realizzarlo deve far convergere le due pretese e questa è una verità non più soggettiva ma comune ad entrambe le parti, quindi oggettiva. Ciò determina la nascita di una regola comune. In questa maniera, le pretese diventano diritti (altrimenti sono solo imposizioni arbitrarie), e questi diritti implicano che le due parti si rendano conto che la regola riconosciuta è obbligatoria per entrambe.

D) L'altro è pari all'io nella capacità di intendere l'obbligatorietà della regola fondata sulla verità comune
Il soggetto-altro è diventato pari al soggetto-io: attraverso la reciprocità del riconoscimento (che evidenzia la razionalità dei soggetti), la pretesa si trasforma in diritto, che è un diritto oggettivo, cioè un diritto-regola. Esso ha superato il diritto-pretesa, e l'io è diventato uomo fra gli uomini.

Possiamo ora tornare al quesito iniziale: autonomia o eteronomia del diritto?
La soluzione: bisogna respingere sia la tesi dell'autonomia (diritto creato dall'io al suo interno), sia quella dell'eteronomia (diritto creato e imposto all'io dall'esterno), in quanto la prima sfocia nell'arbitrio totale, mentre la seconda nella limitazione insostenibile della libertà.
Invece, in base al discorso svolto, il diritto-regola è sì condizionato (quindi non autonomia), ma non da un'imposizione esterna (quindi non eteronomia), bensì dal fatto che l'io ha capito razionalmente che vi sono altri pari a lui, sicchè tutti questi io devono trovare in comune fra loro le norme per regolare i loro rapporti. Questo "trovamento in comune" fa nascere un "diritto comune", perciò non si può parlare né di autonomia né di eteronomia, **bensì di SOCIONOMIA, cioè diritto (nomos=insieme di leggi) in società, in comune.**

CAPITOLO IV: IL FONDAMENTO ONTOLOGICO DELL'ESISTENZA

Riprendiamo in esame "l'individuo empirico", cioè l'individuo visto da un punto di vista oggettivo e non solo soggettivo e possiamo notare che esso ha 3 caratteristiche:

1. **l'incompiutezza**: se l'individuo fosse compiuto, perfetto, non avrebbe la volontà di essere di più, di migliorare il suo essere;
2. **la particolarità**: dal confronto con gli altri soggetti, l'individuo si rende conto di essere diverso da questi, "particolare";
3. **la contingenza**: l'individuo agisce in vari momenti temporali sempre diversi, quindi contingenti.

Quindi l'individuo empirico si rivela non "infinito" ma "finito". Peraltro, l'io vive nel mondo con altri io, per cui il suo esserci è un "con-esserci"; infatti solo se l'io fosse infinito, egli esisterebbe da solo, senza questa dimensione del con-esserci. **E se non ci fosse il con-esserci, il diritto non avrebbe alcun senso**: obblighi e diritti esistono, in quanto vi è il con-esserci umano quale loro necessario presupposto.
E poiché ogni soggetto è caratterizzato dalla sua particolarità, ne deriva che non si ha piena eguaglianza fra i soggetti e questa diversità a volte può essere un ostacolo all'io, mentre altre volte può essergli d'aiuto.

Come può la diversità propria dell'io essere d'aiuto nel relazionarsi con altri io?

Ne vogliamo una prova? Guardiamo a 4 istituti giuridici: ad es. la proprietà, le successioni, le associazioni e i giudizi. Possiamo ritrovarli in tutte le società, da quelle più primitive a quelle più evolute, e ciò accade perché questi istituti soddisfano alcune esigenze fondamentali dell'individuo:

- **La sicurezza**: di poter mantenere i beni, di poterli trasmettere ai figli, di poterli difendere con azioni giudiziarie, ecc.
- **La cooperazione**: dei soci nel mantenimento dell'associazione, degli eredi nel mantenimento della continuità familiare, ecc.
- **La durata**: della famiglia, del possesso dei beni, della propria volontà oltre la morte, ecc.

Tutto ciò dimostra e conferma come il diritto non possa essere autonomo né eteronomo, ma bensì socionomo (DIRITTO IN SOCIETÀ, IN COMUNE).
Essendo l'uomo un essere finito, mancante quindi di qualcosa, è in una posizione di "difettività": l'uomo è in definitiva un ENTE INDIGENTE (privo del minimo indispensabile per vivere), in quanto bisognoso di qualcosa dovuto proprio alla sua finitezza. Questa è la prima caratteristica ontologica (esistenziale) dell'uomo.

Stabiliamo ora il perché dell'indigenza umana.
Cominciamo col dire che se l'uomo si rende conto della propria indigenza (privo del minimo indispensabile per vivere), della propria finitezza, egli ha la capacità di pensare anche all'infinito: solo se confrontato con l'infinito, il finito risulta avvertibile come indigente. L'ente finito si colloca quindi nella prospettiva dell'INFINITO.
D'altronde, il fatto che l'uomo voglia "essere di più", dimostra che egli possiede sia l'idea del finito che l'idea di poter partecipare all'infinito: si pensi alla poesia del Leopardi nella quale la contemplazione di spazi finiti (la siepe) fa sorgere nella mente l'idea dell'infinito.

Riconosciamo allora che la struttura ontologica dell'uomo consiste nella DUALITA', rappresentata dall'unione simbolica fra ANIMA (nella quale vi è la potenzialità dell'infinito) e CORPO (che ne costituisce il limite finito): partendo dalla difettività-indigenza ontologica dell'uomo si arriva alla struttura sintetica di finito-infinito.

Perché è sbagliato non considerare la dualità ontologica e considerare l'Uomo solo indigente e finito?
Ritorniamo al concetto di uomo: se esso fosse "infinito", ciò porterebbe alla negazione dell'alterità, cioè dell'esistenza di altri; se invece si rinchiudesse nella sola finitezza, ciò lo renderebbe incomunicabile con gli altri, mentre invece la relazione interno-esterno (finito/infinito) permette un contatto positivo fra l'io e gli altri io.
Quindi, il mondo nella sua globalità è un sistema relazionale di 2 mondi diversi, ma non separati.

RICAPITOLANDO !!! Vi sono quindi 3 elementi della struttura ontologica umana che seppur differenti, coesistono e coincidono:
1. la difettività indigente
2. la relazionalità interna di finito-infinito
3. la relazionalità esterna di io-altro.

Infine la relazionalità dell'io si manifesta in un importante piano esistenziale, che è quello sessuale, quando, nel rendersi conto di essere uomo o donna, scopre la complementarietà tra i due sessi. La relazionalità dell'io (cioè il fatto che l'io entra in relazione con gli altri) è stata riconosciuta anche dalla psicoanalisi di Freud, che ha stabilito che quando si ritira dal mondo e dai rapporti con i "co-presenti", l'io rinuncia ad una parte fondamentale del suo stesso essere, chiudendosi in una sorta di "autismo schizofrenico".

CAPITOLO V: DALLA STRUTTURA ONTOLOGICA ALLA GIURIDICITÀ.

Abbiamo esaminato la condizione esistenziale dell'uomo: è un essere volitivo e attivo (l'azione dell'uomo non è qualcosa di compatto, ma è la somma di 3 momenti che sono fare-avere-essere: dall'essere si procede

al fare e all'avere dando così origine all'essere ontico), ma anche un soggetto indigente, insicuro e bisognoso dell'aiuto dei suoi simili (i 3 elementi della struttura ontologica umana).

In quanto tale, per sopravvivere deve appoggiarsi ad un insieme di strutture, fra cui quella del diritto (si guardi sopra alle 3 strutture fondamentali che sono: la sicurezza, la cooperazione e la durata):
LA GIURIDICITA' È UNO DEI FONDAMENTI SUI QUALI SI BASA L'ESSERE.

L'uomo si basa su 2 ordini di elementi costitutivi: il finito e l'infinito, il particolare e l'universale, l'anima e il corpo; e l'uomo ha continuamente la possibilità di scegliere fra codeste aree.
La possibilità di scelta presuppone a sua volta la libertà, che quindi deriva dalla dualità interna dell'uomo.
Lì dove c'è discordia Eros/thanatos c'è bisogno di diritto, il mancato superamento del dualismo porta sempre ad una condizione di angoscia, inquietudine, insicurezza.
Se egli non riesce a realizzare la sintesi di questa dualità interna, ha comunque una libertà di scelta ma corre il rischio di arrivare ad atti di estrema violenza, che possono giungere al suicidio o comunque ad attentati all'integrità fisica e morale della persona; se invece si realizza tale sintesi, come detto, si giunge all'affermazione della libertà.

Da ciò deriva quella che deve essere la LEGGE FONDAMENTALE DELLA COESISTENZA: "agisci in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa accordarsi con la libertà di ogni altro, secondo una legge universale". **La teoria dello specchio di Cotta** afferma che io devo specchiarmi nell'altro e l'altro deve specchiarsi in me al fine di raggiungere una parità ontologica, un rispetto ontologico. Quando io vedo nel prossimo un essere inferiore non ho più rispetto dell'altro e tendo a renderlo oggetto e non più Uomo. Kant diceva in uno dei suoi 3 imperativi categorici "agisci considerando il tuo prossimo come fine e mai come mezzo".

E' vero che non sempre l'esistenza realizza in modo uniforme e integrale la coesistenza (omicidio, ripudio del prossimo … possibilità dovute alla libertà di scelta), ma è altrettanto vero che l'esistenza si esprime sempre in forme di relazione co-esistenziale.
Vi sono varie forme co esistenziali, ma tutte determinano ambiti di reciproca comprensione e tutte, soprattutto, si basano sulla GIURIDICITA', con un sistema di diritti e di doveri.

Vi possono essere forme co esistenziali diverse anche perché l'uomo-essere indigente non riesce a risolvere i suoi problemi in modo sempre immediato e globale, ma deve passare per diversi gradi ed aspetti, ma riuscirà sempre a raggiungere una forma co esistenziale adeguata.

PARTE III → ontofenomenolgia delle forme coesistenziali
Lo studio dei fenomeni che portano alla conoscenza dell'essere nella parte terza si concentra sulle forme coesistenziali, ovvero per **Cotta la coesistenza è connessa alla giuridicità (=diritto),** non ci sarebbe diritto senza conesserci o intersoggettività (ad ogni diritto che voglio far valere sull'altro corrisponde un dovere).
L'Uomo in solitudine non ha bisogno del diritto perché vivrebbe in una condizione tale da escludere degli scontri con altri pensieri divergenti e altri esseri. Invece nel mondo **c'è mit da sein (con esserci)** collegata alla giuridicità.
Ogni qual volta mi relaziono con il prossimo o faccio valere le mie idee da solo (homo hominis lupus) oppure con l'ordinamento giuridico.
Cotta analizza solo le principali e più comuni forme coesistenziali e le dividie in 2 branche:
1. Forme coesistenziali integrativo escludenti (amicizia, politica, famiglia) perché tendenzialmente chiuse
2. Forme coesistenziali integrativo includenti (gioco, diritto o giuridica, carità) perché tendenz. aperte

Tutte queste forme sono caratterizzate da 4 Parametri:
1. L'ambito umano di estensione
2. Il principio costitutivo
3. Il movimento d'integrazione
4. Principio regolativo

Forme coesistenziali

	Ambito umano di estensione	Principio costitutivo	Direzione	Principio regolativo
Amicizia	Io-tu	Simpatia	Centripeta	Lealtà
Famiglia	Marito-moglie Genitori-figli	Amore familiare	Centripeta	Fedeltà nella cura
Politica	Noi	Bene comune	Centripeto aggregativa	Solidarietà
Diritto	Universalità degli uomini	Regola	Diffusiva	Legalità
Gioco	Comune interesse universale	Regola	Unitivo diffusiva	Rispetto della correttezza
Carità	Io-tutti	Tutto comprendente	Diffusiva	Accettazione dell'altro

CAPITOLO VI: LE FORME INTEGRATIVO ESCLUDENTI

o L'amicizia

L'amicizia non va intesa né in senso metaforico (amico della natura, amico degli animali, ecc.) né in senso generico (benevolenza, cordialità, ecc.), ma nel suo senso più vero che è quello del rapporto di comprensione-integrazione fra 2 persone.
Un primo elemento caratterizzante dell'amicizia è la particolarità (o dualità) ovvero i suo ambito di estensione: non si può essere "amici di tutti", in quanto l'amicizia si instaura per sua natura si un dualismo "io-tu". Una persona può avere tanti amici, ma non esiste un'"amicizia di gruppo", ma bensì una serie di rapporti dualistici di amicizia parziali.
La vera amicizia per Cotta è quella che può instaurarsi solamente tra due persone.
Il detto: "gli amici dei miei amici sono miei amici" è la forma più generica è povera del termine. L'amicizia vera è per Cotta come una di quelle piccole correnti calde che solcano il freddo Oceano, è unica, immensa, rara.

L'elemento costitutivo dell'amicizia è la simpatia, nel senso letterale della parola di "con sentire" ovvero "sentire insieme", sicché essa non è solo un rapporto affettivo, ma esprime una comunanza di idee, valori, giudizi, ecc., insomma un condividere un medesimo senso della vita, viaggiare sulla stessa onda.
E' proprio la simpatia che permette di fondere due soggetti diversi e renderli un unico soggetto.

Un terzo elemento è la direzione centripeta: dalla dualità fra i due individui si perviene ad un rapporto unitario con direzione verso il centro, in base al quale il "terzo" viene visto come un elemento estraneo e disturbante, per questo l'amicizia è vista come una forma chiusa, escludente.

All'amicizia non basta molto spesso la simpatia per mantenere saldo il rapporto, perché i veri amici debbano potersi fidare uno dell'altro reciprocamente hanno bisogno di un quarto elemento che è la lealtà, principio regolativo fondamentale dell'amicizia.

CONCLUDENDO, l'amicizia rappresenta la forma più elementare di coesistenza che, peraltro, è piuttosto limitata perché se questo rapporto è aperto al suo interno, è però chiuso all'esterno, ed è anche limitato nel tempo, poiché codesto rapporto termina (al più) con la morte di uno dei due soggetti del rapporto duale.
E' chiaro quindi che l'esistenza dell'io non può servirsi solo del rapporto amicale per superare il conflitto derivante dall'incontro con gli altri esserci, non può intendersi, rispettarsi solo con un essere, per altro non può affidare la sua sicurezza su qualcosa di temporaneo.

o La politica

Se l'amicizia è una forma coesistenziale vista sul piano dei rapporti interpersonali, la politica è vista sul piano dei rapporti associativi organizzati.
Fra la relazione politica e la relazione amicale vi sono notevoli affinità, tanto che si suole parlare anche di "amicizia politica" ovvero "amicizia in grande" come diceva Aristotele l'Uomo è un animale politico.
La politica non deve essere intesa come scienza del turismo, dell'economia, della moda ma come modo coesistenziale di vivere, relazionarsi per un ideale politico comune.

Infatti, il primo elemento della politica è quello della "identità sovraindividuale", che accomuna i soggetti

collegati: vi sono gli italiani, i tedeschi, ecc. (sovraindividualità originaria, collegata al luogo di nascita, alle caratteristiche di un gruppo, ecc.), vi sono i soggetti collegati da idee e modi di sentire identici (comunisti, democristiani, ecc.); sicché in definitiva, l'io non si identifica solo nel rapporto "io-tu" dell'amicizia, ma si trasforma nel rapporto "noi".
In questo rapporto, poi, non esiste il "difetto" dell'amicizia di allontanare chiunque non faccia parte del rapporto duale, bensì nell'ambito del "noi" anche colui che rispetto a me è un estraneo, io lo riconosco come connazionale, mio amico e fratello in senso lato.
Il rapporto presuppone pur sempre l'esistenza dell'individuo che lo sostiene, altrimenti si dissolverebbe: nel rapporto politico si instaura quindi un rapporto "io-noi" al posto del rapporto dell'"io-tu" del rapporto amicale; è sbagliato ritenere che l'io si estingue divenendo solo noi ma come sosteneva Marx o Rousseau l'io è la base e tanti io fanno noi.
Un secondo elemento deriva da cosa spinge le varie individualità a riconoscersi nel "noi": è l'esistenza di fattori materiali e spirituali comuni con altri O BENE COMUNE; è la coscienza di una "co-appartenenza", del partecipare ad una comunità, quello che viene classicamente definito il BENE COMUNE POLITICO non a caso le aggregazioni di uomini che conseguono il bene comune sono legate alla politica Commonwealth, Repubblica.
Attenzione: il potere non è l'elemento fondante della politica, ma solo uno strumento da utilizzare per il raggiungimento del bene comune.
Un terzo elemento è la direzione "CENTRIPETO AGGREGATIVA" del movimento di aggregazione: gli appartenenti al gruppo tendono ad aggregarsi in direzione centripeta.
Un quarto elemento è la solidarietà: a differenza di quanto avviene per il rapporto amicale, questo elemento si conserva inalterato nello spazio e nel tempo, permane per gli altri anche se qualcuno del gruppo muore e si sposta altrove. Grazie alla solidarietà l'uomo politico supera le difficoltà ontiche a cui va incontro.

Il rapporto politico si basa anche su un massiccio ricorso al simbolismo: nella politica, a differenza che nell'amicizia, si instaurano rapporti fra le persone ma questi non sempre sono diretti, e di qui la necessità di avere un "simbolo", una sorta di segnale di riconoscimento, che ha la funzione di manifestare l'unità centripeto-aggregativa e solidale che riassume i 4 punti trovati, mediante immagini con riferimenti di tipo parentale (la madrepatria, i fratelli d'Italia, ec.), di tipo cosmico (il globo dell'imperatore medievale, il Re Sole, il caput mundi, ecc.).
Bisogna comunque precisare che diverso dal simbolo è il "mito", che tende a spiegare l'origine di un popolo ed ha quindi una forma narrativa che si rivolge alla ragione, mentre il simbolo si rivolge all'inconscio della psiche.

Abbiamo potuto constatare l'affinità tra amicizia e politica.
Nel passaggio dal duale "io-tu" al plurale "noi", il rapporto perde certo di intensità, ma ne guadagna dal punto di vista della estensione temporale e spaziale.
L'affinità non concerne solo gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi: anche il rapporto politico rimane un rapporto "chiuso", poiché la coesistenzialità resta sempre interna all'ente politico e vive nella particolarità assieme ad altri enti finiti (altri partiti), deformando l'esigenza di infinito. Questo spiega perché i partiti politici tendono internamente a egemonizzare attività culturali come arte, musica, scienze, religione mentre verso l'esterno si limitano solo a evidenziare le differenze dagli altri partiti politici.

Quindi considerando il concetto di politica interna e esterna, abbiamo secondo Bergson 2 concetti: "homo homini Deus" (che riguarda i concittadini e significa appunto l'Uomo per l'altro Uomo è un Dio) e "homo homini lupus" (che riguarda gli stranieri e significa l'Uomo per l'altro Uomo è un lupo): quanto più il rapporto politico è integrativo e pacificante all'interno, tanto più è separante all'esterno, sicché anche qui il "terzo" è visto come un elemento di disturbo; se la politica tende a far sparire il ricorso alla forza sul fronte interno, tende invece ad esaltarne il ricorso sul fronte esterno: la politica vive di una dialettica antinomia "amicizia-inimicizia".
Vedi l'esempio dello stato d'Israele affidato agli ebrei: finché il popolo ebraico non ha riformato un gruppo politico, è vissuto pacificamente, ma non appena si è ridato una forma politica, subito è entrato in conflitto con gli Stati vicini palestinesi.

È possibile superare questa ambivalenza della politica? Non sembra possibile, in quanto propria della

struttura stessa della politica: se la politica mira a realizzare il bene comune, è chiaro come l'"estraneo" non vi abbia parte e quindi visto in senso ostile.
Si può pensare di superare questa ambivalenza allora organizzando il mondo intero come un'unica polis, un'unica cosmopoli, una sorta di Impero senza più "stranieri"? Anche qui non ci siamo: anzitutto si deve rilevare che se l'Impero nasce non dal consenso spontaneo ma dalla conquista, non fa altro che portare l'inimicizia all'interno, addirittura annullando il vantaggio della politica; poi ancora si deve rilevare che la storia ci insegna che il momento in cui un Impero raggiunge l'acme della sua estensione segna anche l'inizio della sua decadenza, come se il movimento centripeto-aggregativo non riesce a superare un certo limite di estensione.

Allora deve concludersi che bisogna riconoscere che anche la politica non riesce ad eliminare del tutto l'insicurezza esistenziale, poiché anche in essa continuano a convivere amicizia e inimicizia alimentandosi reciprocamente.
Sicchè la guerra sembra essere legata alla politica in maniera strutturale. Von Clausewitz affermava che "la guerra è un seguito del procedimento politico con altri mezzi".
Basti pensare che la guerra possiede la stessa ambivalenza della politica: amicizia fra commilitoni e inimicizia verso gli avversari; con ciò non si vuol dire che la politica sia condannata ad una guerra continua, che anzi si tende ad evitare, anche se però i relativi mezzi sono inadeguati: le stesse alleanze (fra Stati, classi sociali, ecc.) sono sempre "contro" qualcuno.
Lo stesso avviene in quella raffinata teoria moderna detta **"teoria dei giochi":** basandosi su una raffinata serie di calcoli, tende ad ottenere il massimo vantaggio, evitando il massimo rischio della guerra prevendo le mosse dei nemici; anche questa teoria in definitiva non elimina la figura del nemico ed anzi la presuppone come fondamento di tali studi, il che va comunque contro una pacifica e unitaria forma di coesistenzialità.

- La famiglia

La famiglia si presenta come un tipo di relazione interpersonale doppiamente complessa, in quanto si articola su 2 livelli (ognuno dei quali a sua volta bidimensionale):

- primo livello: è il livello di base che si articola su due dimensioni, che sono quella "biologico-naturalistica" (la eterosessualità) e quella "umano-spirituale" (lo stretto contatto esistenziale che nasce fra l'uomo e la donna).
- secondo livello: si articola su due dimensioni personali, che sono la dimensione "orizzontale" (marito-moglie) e quella "verticale" (genitori-figli).

Quindi, la caratteristica che distingue la famiglia dall'amicizia e dalla politica consiste in questa duplice bidimensionalità, mentre nelle altre due vi è solo il rapporto umano-spirituale e non esistono sessualità e genitorialità.
È vero che in alcuni rapporti può mancare ad es. la genitorialità (genitori senza figli) o la eterosessualità (famiglie omosessuali), ma in tal caso si tratta di eccezioni che non vanno ad inficiare la regola generale. In particolare poi, per quanto riguarda la relazione omosessuale, questa non potrebbe dare mai origine ad un vero rapporto familiare in quanto non può dare origine alla genitorialità e in quanto porta inevitabilmente ad una alterazione esistenziale di uno dei due partners che assume l'aspetto del sesso mancante senza però averne la sostanza psicosomatica, e diventando perciò solo un "essere come" ma pur sempre altra cosa rispetto alla famiglia.

Vediamo ora le CARATTERISTICHE strutturali del rapporto familiare.
L'ambito umano sul quale esso si basa è strettamente personale, e si fonda sulla dualità del rapporto marito-moglie e sulla pluralità del rapporto genitori-figli, assimilandosi per il primo aspetto all'amicizia e per il secondo alla comunità politica.
Vi sono però poi delle DIFFERENZE: rispetto all'amicizia manca la simpatia, che si trova solo all'inizio, al momento dell'innamoramento che porta poi all'unione matrimoniale; rispetto alla politica manca il concetto del bene comune, che porta ad una identità sovraindividuale, in quanto nel rapporto marito-moglie ci deve essere una parità ontologica e i due individui rimangono pur sempre due diversi esseri.

Vediamo quindi l'elemento che caratterizza in pieno il rapporto familiare aggregandolo, rendendolo unito: nella famiglia rimane una dualità tra uomo e donna che, pur integrandosi, rimangono distinti: **l'amore**

reciproco rende le persone "complementari", ma pur sempre desiderose di rimanere "uno e altro" senza ridurre l'altro a copia depersonalizzata ma imparando costantemente dall'altro.
Lo stesso amore si ritrova nell'amore genitoriale verso i figli, frutto di questo amore che lo sorregge e lo prolunga fecondamente nel tempo.
Se alla base della famiglia vi è un sentimento adulto e convinto si trova la forza di superare tutte le difficoltà e spesso oggi si perdono battaglie d'amore troppo facilmente perché si è così codardi da scappare. Le difficoltà fanno parte dell'esistenza umana e dell'essere sintetico razionale (finito/infinito) dell'Uomo e bisogna affrontarle.

Per quanto concerne poi il **dinamismo aggregativo**, anche nella famiglia esso è centripeto e quindi escludente nei confronti dei non appartenenti alla stessa, anche se tale chiusura non è assoluta, poiché si riconosce il sistema delle "parentele". Inoltre l'amore familiare è congregativo anche per altre famiglie che si riconoscono in sentimenti comuni e si aiutano vicendevolmente (fenomeno religioso di aiuto fra famiglie) in quanto vivono simili situazioni e porta a con-gioire, con-fortare ecc. Inoltre il matrimonio non è vincolato alla condizione della con cittadinanza, poiché i rapporti familiari superano i confini politici e culturali in virtù proprio dell'amore elemento aggregativo straordinario.

Ed allora ecco che emerge **il principio che regola il rapporto familiare**: poiché ciò che costituisce la famiglia è "l'amore interpersonale aggregativo", ne consegue che il principio regolativo della famiglia è quello della FEDELTA' e CURE RECIPROCHE, la c.d. FEDELTA' NELL'AVER CURA ovvero genitori si prenderanno cura dei figli e i figli a loro volta (nella c.d. inversione fisiologica) si prenderanno cura dei loro genitori quando questi si comporteranno come figli.

La famiglia spesso viene denominata "società naturale", e tale definizione è esatta; essa è infatti "naturale" in quanto nasce insieme con l'homo sapiens, perché costituisce lo sbocco tipico delle esigenze affettive e di conservazione dell'uomo e nasce in maniera "originaria", cioè non per ordine di un'autorità esterna o di leggi eteronome ma per esigenza propria delle persone.
Da ciò deriva che non è possibile stabilire cosa nasca prima tra famiglia, società e Stato: probabilmente essi sono coevi.

CONCLUSIONI
In definitiva possiamo dire che amicizia, politica e famiglia sono forme coesistenziali dotate di alto grado di integrazione: hanno perciò una innegabile efficacia nel conferire sicurezza ai soggetti esistenti; pur tuttavia bisogna riconoscere che esse comportano anche una profonda esclusione delle altre persone che non partecipano alla relazione amicale, politica o familiare.
Da ciò deriva che le forme coesistenziali non si esauriscono e non possono esaurirsi con esse, sicchè la ricerca di altre forme che soddisfino i lati evasi delle integrativo-escludenti deve continuare.

CAPITOLO VII: LE FORME INTEGRATIVO -INCLUDENTI

PREMESSA. Le forme coesistenziali integrativo-escludenti sono selettive perché si stabiliscono soltanto fra coloro che condividono un "idem sentire" inscritto nella particolarità. Perciò sono escludenti.
Né la politica, né l'amicizia, né la famiglia costituiscono l'intiero dell'umano e necessitano di altre forme dette integrative includenti che consentono agli appartenenti una possibilità di comunicazione con l'esterno superando così il momento della particolarità.
La particolarità non si accontenta più della "simpatia", del "bene comune", dell'"amore familiare", ma cerca nuove forme, e fra queste troviamo quelle del gioco, del diritto in senso stretto, della carità: forme coesistenziali che non instaurano più rapporti particolari (con determinate persone), ma universali (con chiunque), quindi di tipo integrativo-includente.

- Il gioco

A prima vista può meravigliare che si attribuisca al gioco una tale importanza, tuttavia esso è una forma coesistenziale fra le più antiche dell'uomo; è una forma anomala perché esiste anche il gioco insano, quello escludente ma Cotta indica come gioco la forma esistenziale più pura, quella dove predomina la parte includente. Perché le persone si pongano in una relazione ludica non è necessaria né la simpatia

dell'amicizia né l'identità sovraindividuale della politica né alcun vincolo di appartenenza familiare: essa si basa **(ambito)** solo su una personale "LIBERA SCELTA", poiché nessuno è obbligato a giocare; tale libera scelta è originata da un "COMUNE INTERESSE" a giocare, sia pure per diversi motivi (Secondo Platone il gioco distrae dalla riflessione del pensiero della morte oppure motivi intellettuali, economici); tale condizione può essere soddisfatta da qualsiasi individuo, sicché il gioco è aperto per tutti.

Il secondo elemento è che il gioco **ha bisogno di REGOLE** (ad es. la regola fa la differenza fra il pugilato e il prendersi a pugni in una rissa). La prima regola è quella secondo la quale i contendenti partono da una situazione iniziale di PARITA', il che implica il loro reciproco riconoscimento e toglie alle loro diversità il carattere di estraneità ed esclusione. **Il gioco quindi si basa sul principio di LEGALITA'**: se vi sono delle regole, queste devono essere rispettate, il che comporta la necessità della presenza di un giudice e di punizioni per le trasgressioni.

Attenzione: la relazione ludica pretende non solo il rispetto della legalità "formale" ma anche il rispetto della persona dell'avversario, quindi rispetto della legalità significa anche rispetto della **CORRETTEZZA** che è principio regolativo.

Il gioco quindi ha una direzione centrifuga diffusiva (si diffonde a tutti coloro che aderiscono a quel gioco senza escludere chi voglia giocare, ma includendo chiunque per libera scelta e comune interesse si unisca).

Tuttavia, la coesistenzialità ludica ha peraltro dei limiti e per tali difetti deve ammettersi che la relazione ludica non esaurisce la soddisfazione dell'umana esigenza di coesistenzialità:

1. è limitata alla "categoria dei giocatori" ed esclude comunque coloro che nella libera scelta non scelgono di giocare
2. unisce i giocatori su un iniziale piano di parità, ma ha pur sempre come scopo finale quello della vittoria di una parte sull'altra, sicchè anche il gioco genera "asimmetria" e perciò è "disgiuntivo".

- Il diritto

Il diritto, o per meglio dire la "coesistenza secondo il diritto", realizza una fondamentale forma di relazione interpersonale aperta e non chiusa come la politica. Sotto un certo punto di vista, il diritto viene considerato come una relazione giuridica che dipende dall'ente politico che lo impone (lo Stato, la tribù, ecc.) e quindi viene visto come una sorta di "sottosistema" del sistema politico, sicché non darebbe luogo ad una forma coesistenziale propria.
Ma questa tesi risulta errata: certo non vi è ente politico in cui sia assente il fenomeno giuridico, e questo anche perché il diritto rende più sicura l'esistenza e la durata dell'ente politico: esso è di supporto al processo di autocoscienza dell'io nel noi e ne garantisce l'efficacia con la propria obbligatorietà, e da ciò si potrebbe dedurre che il diritto sia una sorta di fenomeno interno e subalterno alla politica, quindi anch'esso chiuso nella particolarità dell'ente politico.
Tuttavia, malgrado la rilevante presenza di un diritto "dipendente" alla politica, in quanto collegato all'ordinamento giuridico di quell'ente politico, può dirsi che l'ordinamento giuridico è diritto, però esso non esaurisce il fenomeno giuridico generale che ha una portata ben più ampia.
In sostanza, il diritto supera il ristretto campo della politica, poiché i rapporti giuridici che vengono ad instaurarsi fra gli uomini travalicano i limiti più o meno ristretti dei singoli enti politici cui essi sono collegati: ad es. si stipulano contratti, nascono rapporti giuridici, ecc. anche fra persone e gruppi non appartenenti al medesimo ente politico; quindi il diritto ha la capacità di estendersi universalmente prescindendo dalle preclusioni dovute alle chiusure politiche, secondo il principio "io sono tenuto a comportarmi in un modo come l'altro è tenuto a comportarsi nello stesso modo pena sanzione".
Quindi possiamo affermare che il primo elemento strutturale del diritto è il principio della UNIVERSALITA'.
Ma come si fa a stabilire rapporti di comprensione e collaborazione in un ambito esteso universalmente?
E' evidente che occorre reperire una REGOLA COMUNE DI COMPORTAMENTO.
Ovviamente, le regole esistono anche nei modi coesistenziali di vivere già esaminati, ma in questi risultano solo degli elementi "accessori", tanto da non poter sussistere senza quelli: ad es. un rapporto amicale basato solo su regole non sarebbe autentico, forzato e quindi effimero.

Invece nel rapporto giuridico, la regola è presente nella purezza del suo concetto, si identifica in esso e non conosce alcun limite. Perciò possiamo affermare che **la REGOLA** sia il principio costitutivo del rapporto giuridico. Grazie alla regola, i comportamenti umani possono essere inquadrati in maniera oggettiva: essi risultano "regolari" o "irregolari"; e nasce così la possibilità di eliminare ogni incertezza ed ogni insicurezza. **Il rapporto "io-altro" assume la massima estensione e stabilità e consente l'apertura della coesistenza alla totalità degli uomini.**

E qual è la DIREZIONE della relazione giuridica? Essa non è di tipo "centripeto-escludente" ma, data la sua universalità, è di tipo **"DIFFUSIVO- includente"**; si pensi alla regola "non uccidere": essa non può considerarsi limitata solo ai membri di quel gruppo sociale e politico ma ha valenza universale; un contratto può riguardare anche un numero minimo di persone (solo 2), ma i contraenti sono sostituibili all'infinito e inoltre la regola del contratto non prevede discriminazioni ma è aperta a chiunque purché con capacità di intendere e volere. D'altronde esistono tanti esempi di regole giuridiche sovranazionali (si pensi al diritto romano, al diritto islamico, alla common law anglosassone): sistemi giuridici nati in singoli Stati, poi estesi quando tali Stati sono diventati Imperi e poi rimasti anche quando questi si sono frantumati e ciò vale a confermare la "diffusività" della regola.

Possiamo quindi dire che il diritto ha un principio costitutivo universale (la regola) e ha un dinamismo diffusivo.

Il diritto offre in ogni caso una pacificazione fra gli uomini, assumendo dunque un SIGNIFICATO PACIFICO, e ciò vale ulteriormente a distinguere la relazione giuridica da quella politica.

Ultimo elemento strutturale del rapporto giuridico, in base al quale esso rimane integro al di là della variabilità dei soggetti, è il PRINCIPIO DI LEGALITA': basta rispettare la regola perché il rapporto giuridico permanga nella sua autenticità.

DIFFERENZE DALLA RELAZIONE LUDICA.
- Abbiamo visto come il gioco sia "congiuntivo" all'inizio ma "disgiuntivo" alla fine, mentre invece la parità esistenziale nel diritto si mantiene e si protegge sempre. Attenzione: si potrebbe pensare che di una disputa giudiziaria vi sia chi vince e chi perde alla stessa stregua che in una relazione ludica, ma in realtà la vittoria realizzata nella disputa giudiziaria mira proprio a ripristinare la parità iniziale fra le parti che il comportamento illecito di una delle due aveva alterato. Quindi il diritto è "congiuntivo" fino alla fine del suo procedere ed anzi realizza in questa sua caratteristica un suo fine precipuo.

- Giocare è una libera scelta, non un obbligo; per il diritto è diverso, in quanto è vero che si è liberi di compiere o meno un atto giuridico e si può addirittura rifiutare in blocco l'intero sistema giuridico, ma in tal caso si mette in gioco la propria esistenza poiché si rinuncia alla propria coesistenzialità aperta e ci si confina nell'isolamento regressivo: quindi il modo di vivere giuridico è eliminabile solo a condizione di mutilare il processo di autocoscienza.

TIRIAMO LE SOMME: nel rapporto giuridico, gli individui realizzano una coesistenzialità universalmente aperta, nella quale è possibile sia il riconoscimento dell'essere dell'altro, sia il potenziamento del proprio essere; inoltre grazie alla mediazione della regola comune, questo riconoscimento viene sottratto alla soggettività delle singole persone e diventa valutabile in maniera oggettiva, con esclusione di ogni tipo di violenza.

- La carità

La carità è l'ultima delle forme coesistenziali analizzate. Nella carità si parla di un rapporto ternario e non duale perché ci siamo Io, Tu e Dio (Dio inteso come un'entità superiore che sovrasta la natura umana alla quale l'Uomo si rivolge e può essere la stessa Umanità).
Indubbiamente la carità è strettamente correlata alla prassi del Cristianesimo "amore per il prossimo come te stesso", che a sua volta si riporta a forme simili quali l'eros platonico, la philia di Aristotele, ecc. e soprattutto a quella versione più "secolarizzata", cioè al di fuori della prassi di tipo religioso, che è la FILANTROPIA= amore per l'Uomo.

Il primo elemento strutturale è l'UNIVERSALITA' DEL SUO AMBITO UMANO nel senso di rendere il prossimo come se stessi e rendere il particolare parte di un progetto più grande, parte di un'umanità che assieme al resto della natura fa parte di un progetto divino più grande.
Ma qual è il suo PRINCIPIO COSTITUTIVO? Cosa induce l'io ad accettare gli altri indipendentemente dalle loro caratteristiche particolari? Come può l'io aprirsi al tutto? Ciò si verifica perché l'io si rende conto di far parte di un TUTTO (Uomini + natura sintetizzati in un Dio) nel quale ogni uomo è com-preso, e ciò perché esiste un TERZO che riesce a fare da mediatore fra le diversità e le rende reciprocamente comprensibili. Quindi il principio costitutivo della carità è il TUTTO COMPRENDENTE.
Il terzo elemento della carità è il DINAMISMO DIFFUSIVO su cui essa si basa, che procede dal soggetto e si diffonde verso ogni uomo in base al principio regolativo dell'ACCETTAZIONE DELL'ALTRO, riconoscere l'altro parte di un tutto e aiutare il prossimo così come si vorrebbe essere aiutati nel momento del bisogno.

- Differenza fra carità e amicizia: l'amicizia tende sempre ad instaurare un rapporto particolare con un altro soggetto specifico, mentre la carità tende alla UNIVERSALIZZAZIONE del rapporto dirigendolo nei confronti del "prossimo", cioè "chiunque".
Nell'amicizia vi è un rapporto dualistico "binario", mentre nella carità si costituisce un rapporto "ternario", in quanto oltre alle due persone vi è un terzo soggetto, che possiamo ravvisare in Dio (o l'Umanità nel caso della filantropia, versione sociale della carità), che rende possibile l'instaurazione del rapporto "io-tutti".
- Differenze fra carità e famiglia: l'amore parentale e coniugale è sicuramente più ricco rispetto all'amicizia, però rimane pur sempre un rapporto chiuso, distinguendosi dalla carità che invece è un rapporto di amore verso il prossimo aperto.
- Differenza tra carità e politica: quest'ultima dà sempre origine ad una forma di coesistenza chiusa.
- Differenza tra carità e diritto: malgrado la caratteristica di universalità sia di entrambi, si può iniziare ricordando che il rapporto giuridico trasforma sempre i suoi membri in soci e presuppone l'esistenza di organi istituzionali e di regole tipiche, mentre il rapporto caritativo intercorre sempre fra persone, fuori da ogni schema organizzativo; la giustizia si concreta in una parità di trattamento ed esige reciprocità di diritti e doveri, mentre la carità prescinde da questa parità e reciprocità. Infatti il baratto DO UT DES tipico del diritto nella carità non chiede nulla in cambio, **io do carità gratuitamente senza doppi fini di lucro**.
Inoltre un ulteriore differenza è che il diritto è armato perché se io non sottostò ad un accordo diritto/dovere allora ho una sanzione, invece nella carità io compio qualcosa perché lo sento dentro e non è armata come il diritto ma disarmante.

La carità costituisce un modo di vivere del tutto originale, che realizza una coesistenzialità tesa ad aver cura degli esistenti e ad amarli solo per il fatto stesso della loro partecipazione all'Essere.

L'unica forma coesistenziale sprovvista di giuridicità è proprio la carità che racchiude a massima espressione di coesistenzialismo, l'Uomo riconosce il suo prossimo e senza egoismo si mette a disposizione del prossimo, accettandolo e non imponendosi al di sopra con l'arroganza di ritenersi migliore.

CAPITOLO VIII: GIURIDICITÀ E DIRITTO IN SÉ: UN BILANCIO

Il quadro delle forme coesistenziali sin qui delineato non è completo, poiché ve ne sono altre: fra queste ricordiamo in particolare la relazione economica e quella estetica (per quest'ultima non si intende la relazione imperniata sulla bellezza quale armonia globale, ma piuttosto quella basata sull'"EGOTISMO", che può essere considerata una forma di esistenza e non coesistenza dal momento che non rispetta la parità tra i soggetti ma attribuisce ad altri giudizi soggettivi differenti.).

In ogni caso le 6 forme coesistenziali esaminate sono sufficienti a comprendere la condizione umana: esse sono differenti fra loro e tuttavia coesistono, poiché tutte hanno un elemento comune: la GIURIDICITA'. Inoltre hanno tutte in sé un principio regolativo, quello della DOVEROSITA', si devono rispettare al fine di poter avere una coesistenza tale che senza questa doverosità non si potrebbe costituire: lealtà amicale, solidarietà politica, cura familiare, correttezza ludica, legalità giuridica, accettazione caritativa.

Torniamo all'elemento comune della GIURIDICITA'. Esso sussiste sì in tutte le forme, ma un po'

particolare è il caso della relazione caritativa, in quanto questa è forse l'unica a non richiedere un vero sistema di regole, perché non chiede reciprocità né la impone e quindi il suo rapporto con il giuridico è del tutto atipico.
La giuridicità è diversa in relazione alle varie classi di relazioni coesistenziali (subalterna, costitutiva):

1. forma amicale, politica e familiare: **la giuridicità è "subalterna",** nel senso che essa non è necessaria per far sorgere queste forme di relazioni e serve solo per garantire l'uniformità dei relativi comportamenti; inoltre qui la giuridicità è di tipo "particolare", perché riguarda forme integrativo-escludenti e non è applicabile oltre i loro confini
2. forma ludica e del diritto: qui la **giuridicità è "costitutiva"** perché senza di essa, senza le regole, tali forme di relazione non possono nascere; è inoltre di tipo "universale", poiché le relative forme sono aperte all'esterno senza confini, essendo integrativo-includenti.

Altra differenza fra le varie classi è quella che valuta come la regola giuridica si rapporta all'uomo: nella prima classe, l'uomo viene preso in considerazione come diretto destinatario (amico, concittadino, coniuge, giocatore), nella seconda è presa in considerazione direttamente la regola e non l'uomo, ed è la forma della coesistenza giuridica.

CAPITOLO IX: LA FUNZIONE DEL DIRITTO

Passiamo ad esaminare il quesito su QUALE SIA LA VERA FUNZIONE DEL DIRITTO.
Il problema non si è posto fino a che si è sostenuto che il diritto facesse parte della stessa natura dell'uomo, che fosse insito in esso; ma ad un certo punto questa teoria è stata superata, ed ecco allora sorgere il problema di come giustificare l'esistenza del diritto, stabilire la sua funzione.
Si è passati allora ad altre teorie: ad es. si è detto che il diritto avesse la funzione di proteggere valori umani e sociali quali la libertà, l'uguaglianza, l'ordine, la giustizia sociale; poi si è detto che avesse la funzione di proteggere gli interessi e di comporli, risolvendo le controversie e punendo gli illeciti.
Ma tutte queste teorie non sono risultate "conclusive": così ad es. la tutela dei valori può ottenersi anche mediante altre forme come la persuasione, l'educazione, ecc., mentre le controversie possono anche essere risolte in termini di amicizia, amore familiare, filantropia, ecc.
In realtà tutte queste teorie sbagliano perché si fondano su un errore di base, che è quello di ritenere che il diritto sia solo uno strumento per perseguire valori o scopi che però non gli appartengono, sicchè esso avrebbe una funzione solo "formale", basandosi solo sulla forma "prescrittivo-sanzionatoria".

Questa tesi è alla base delle cc.dd. TEORIE RIDUZIONISTICHE, che negano al diritto una sua essenza.
Fra queste teorie ricordiamo:

- la teoria riduzionistica di MARX: il diritto è solo una sovrastruttura del sistema economico della produzione, poiché serve per assicurare al capitalista la proprietà dei mezzi di produzione da cui dipende il dominio della classe proletaria; e addirittura Marx arriva a prevedere la scomparsa del diritto nella società comunista, priva di classi (il che è un'illusione, in quanto il sistema di produzione esige sempre, anche scomparendo le classi, un'organizzazione che a sua volta ha bisogno della formalizzazione di regole di comportamento)
- la teoria riduzionistica di CROCE: egli sposta l'attenzione dal rapporto materiale in senso stretto, come organizzazione della produzione, e lo riduce al diritto privato empirico, limitato alla regolamentazione degli affari economici.
- la teoria di Carl SCHMITT: è la teoria che riduce il diritto alla politica. Una scuola di pensiero sostiene che la norma abbia la sua fonte nel Sovrano che decide le leggi e ne è anche l'unico interprete (Hobbes primo sostenitore) e poiché il Sovrano e la sua summa potestas sono "fatti politici", ne deriva che anche il diritto ha sostanza "politica": concezione detta anche del "NORMATIVISMO" (in realtà Schmitt vede il fondamento storico della norma non nel Sovrano ma nella comunità politica, ma il risultato è il medesimo)
- secondo altri: il diritto è determinabile solo in base alla sua effettiva capacità sanzionatoria (vedi KELSEN), sicchè si presenterebbe come "FORZA" e sussisterebbe nella misura in cui questo uso della forza sia efficace.

Poiché il riduzionismo oggi più diffuso tra gli studiosi è quello politico, è opportuno cercare di chiarirne il retroterra culturale. A mio parere è costituito dalla filosofia di Hegel: oggi in genere ripudiata sul piano politico, essa resta decisiva per intendere il pensiero giuridico moderno, data la sua capacità filosofica di interpretarne la tendenza nell'arco di tempo che dal secolo XVII circa giunge sino a noi.

Lo Stato hegeliano non è affatto una costruzione monolitica né una mera struttura del potere; è invece la realizzazione della piena autocoscienza di un popolo, la piena realizzazione dell'eticità, ciò che i suoi predecessori giusnaturalisti moderni non avevano affermato e né i suoi successori hanno accettato.
Lo Stato è per Hegel, come per Aristotele una famiglia in grande, supera le contraddizioni della società civile e giunge ad una sintesi. Hegel è il primo che fa una distinzione tra società civile (regna l'individuo, atomismo) e Stato dove si parla di cittadino con diritti e doveri. Lo stato di Hegel è di diritto perché prende la legittimità dal diritto positivo.

In ogni caso, egli ha inteso il proprio tempo come tempo dei popoli e dello Stato di popolo, interpretando il fenomeno giuridico entro questa generale prospettiva filosofica.
Pertanto con Hegel si attua il rovesciamento radicale della concezione classica del diritto: da realtà superiore allo Stato (quindi suo fondamento nonché limite normativo) a realtà derivante e dipendente dallo Stato.

In nome della eticità dello Stato, il diritto è quindi risolto da Hegel nell'ordinamento giuridico positivo raccolto nella Costituzione, che esprime la volontà storica di un popolo autocosciente. (Perciò al di sopra del diritto statale non vi sarebbe per Hegel alcun diritto, poiché quello che noi chiamiamo diritto internazionale non sarebbe che un "diritto statale esterno").

Senza dubbio, dopo Hegel sono state progressivamente abbandonate la sua giustificazione etica della riduzione del diritto all'ordinamento statale e, ancor più, la sua negazione del diritto internazionale; ma il fondo della sua tesi è rimasto e fornisce il quadro entro cui la scienza giuridica odierna interpreta il diritto.

Per superare le teorie riduzionistiche sin qui esposte, occorre tornare alla visione classica del diritto, quella del "DIRITTO NATURALE", anch'essa inizialmente superata, ma con modi nuovi e attraverso strade nuove.
Il nostro tempo è diverso da quello dell'epoca dell'autosufficienza dei singoli popoli e la nostra è diventata l'epoca della necessaria comunicazione e collaborazione internazionale, poiché nessun popolo ormai basta a sé stesso.
Nella duplice prospettiva di una necessaria comunicazione universale e di una minaccia comune (ad es. la bomba nucleare), gli uomini si trovano oggi parificati fra loro: il nostro è un tempo di transizione, in cui si sta passando dall'età delle patrie separate e degli ordinamenti giuridici particolari all'età degli uomini, dell'unica patria e dell'unica legge che ingloba le patrie e le leggi particolari.

Ed ecco che si stabilisce quale è la VERA FUNZIONE PROPRIA DEL DIRITTO:
realizzare la coesistenza nella legalità universale, che non è solo un fatto formale ma soprattutto sostanziale ben preciso, poiché è basata sul riconoscimento dell'eguaglianza degli individui, il che comporta la realizzazione della compatibilità delle loro libertà esistenziali.
Peraltro l'individuazione di questa funzione specifica del diritto è da sempre presente nella coscienza comune, che ha sempre visto la "giustizia" come qualcosa che trascende la legge, la regola, che alla giustizia deve essere subordinata.
Ovviamente non va sottaciuto che, a volte, il diritto sia stato usato per fini diversi (ad es. rinsaldare il potere politico) e che siano state emanate delle leggi antigiuridiche, ma è proprio in questi casi che si può vedere come tali aberrazioni siano state determinate dal fatto che il diritto sia stato utilizzato come un MERO STRUMENTO e ciò dimostra con maggiore forza la tesi esposta.
Anche l'amicizia, la carità possono essere usate come strumenti per il vantaggio personale del singolo o di un gruppo, ma nessuno oserebbe affermare che tale è la loro funzione e lo stesso avviene allorché il diritto venga strumentalizzato dalla volontà del potere.
In definitiva, possiamo ora riconoscere che IL DIRITTO HA UNA SUA FUNZIONE SPECIFICA non formale**: attuare la legalità universale secondo giustizia, garantendoci nei nostri rapporti**

intersoggettivi. Il che fa prevalere i diritti dell'uomo su quello del cittadino, universali i primi, particolari i secondi.

PARTE IV → giuridicità (diritto) e giustizia
CONCETTI ESSENZIALI ripetere bene
Dire giuridicità è come dire diritto. La IV parte si occupa dunque di diritto e giustizia.
La funzione del diritto è quella fondamentale di tutelarci nei nostri rapporti intersoggettivi.
In Cotta il diritto è un modo di vivere autenticamente coesistenziale e se non ci fosse MIT DA SEIN (conesserci) non ci sarebbe conflitto e quindi non ci sarebbe bisogno del diritto.
La funzione del diritto per Cotta è quella di attuare la legalità universale (fare leggi condivisibili per tutti) secondo il valore della giustizia, **giustizia che per Cotta è il trascendentale** (= non si può parlare di norma giuridica a prescindere dalla giustizia; trascendentale non va confuso con trascendente in quanto trascendente significa ciò che sta al di la, ciò che non si conosce invece trascendentale è ciò che è aldiquà, un apriori, non ha bisogno di essere di dimostrato ma lo si da per scontato e in funzione di questa distinzione possiamo dire che Cotta vuol dire che non si può parlare di norma giuridica a prescindere della giustizia).
La regola giuridica è una proposizione linguistica (secondo Austin esiste il linguaggio ontico o dell'essere, quello deontico o del dover 'essere e il linguaggio aletico o della verità) che rispetto alla regola delinquenziale è caratterizzata da una convinzione e dall'obbligo (la norma giuridica è obbligatoria perché conforme al valore, quindi al bene e alla giustizia) e non dalla costrizione e dalla forza bruta (conforme al disvalore).
Importante è la distinzione tra l'avere un obbligo (soggetto attivo, sono io che mi sento obbligato ad un certo comportamento) ed essere obbligati (soggetto passivo, sono obbligato a te quindi non sono io a decidere autonomamente)
Il rapporto che intercorre tra regola giuridica e giustizia secondo S. Agostino la legge concorda con la giustizia perché è impossibile che esista una regola non giusta.
Per la dottrina classica infatti dire legge è ugualmente dire giustizia in quanto è impensabile una legge non giusta; tuttavia con Kelsen si ebbe una sorta di rivoluzione copernicana e si disse che la giustizia era un ideale irrazionale, una felicità sociale, la norma giuridica doveva essere puramente positiva esente da caratteri valoriali e spirituali, solamente norma.
Cotta dirà che la giustizia, quella universale=universalmente condivisibile, rispetta l'ontologia dell'Uomo e **costituisce il trascendentale della regola**, **giustizia che per Cotta è il trascendentale** (= non si può parlare di norma giuridica a prescindere dalla giustizia; trascendentale non va confuso con trascendente in quanto trascendente significa ciò che sta al di la, ciò che non si conosce invece trascendentale è ciò che è aldiquà, un apriori, non ha bisogno di essere di dimostrato ma lo si da per scontato e in funzione di questa distinzione possiamo dire che Cotta vuol dire che non si può parlare di norma giuridica a prescindere della giustizia).
Inoltre per la dottrina classica dire diritto e dire illecito erano cose distinte invece con Kelsen si disse che l'illecito è conditio sine qua non perché possa esistere il diritto riassunto nello schema
"SE A ALLORA B" → se c'è illecito allora c'è sanzione. Kelsen venne attaccato perché non da una definizione di giustizia e non la da perché se la desse, cadrebbe tutto il suo pensiero positivistico.
Per Kelsen la legge non viene scoperta dal legislatore perché esistente già in natura ma viene creata "la norma è frutto di un volere" e quindi Kelsen dirà che la legge è creata dall'autorità e non dalla verità e ciò è sbagliato perché non si può ridurre il diritto, frutto umano, a qualcosa di formale.
La norma giuridica per Kelsen è costituita da una struttura piramidale dove al vertice c'è la groundnorm che è formata da una sua validità presupposta e non posta come le normali norme ordinarie che attingono le loro validità dalle norme che le precedono ad infinito fino a quando il regresso all'infinito si pone la norma fondamentale.

Per Cotta, le regole giuridiche sono sentite come obbligatorie quando si basano sul principio della giustificazione basato sulla funzionalità coesistenziale della prescrizione (coincidenza col valore fondamentale di giustizia). Invece, le teorie attuali come Kelsen non considerano l'obbligazione alle norme giuridiche come legati alla giustificazione ma alla validità e l'effettività: una norma è obbligatoria se valida ed è valida se inserita nell'ordinamento
(Quando è valida una norma? Una norma è valida quando ha un'esistenza specifica in un dato ordinamento giuridico. Invece una norma è efficace se il comportamento prescritto da tale norma è realmente assunto dai

soggetti.
Secondo Kelsen, la validità VIENE ACCERTATA mediante un controllo di coerenza formale e contenutistica con le altre norme superiori nell'ordine gerarchico delle norme fino ad arrivare ad una presupposta norma fondamentale. Questa groundnorm però si basa su un presupposto non giustificato, tutte le norme dipendono dalla groundnorm che di fatto non è giustificato.

CAPITOLO X: LA REGOLA GIURIDICA E LA GIUSTIZIA

Si è visto sin qui come in tutte le forme coesistenziali vi sono sempre delle regole ("giuridicità"), sicché puntiamo ora la nostra attenzione sul concetto di REGOLA.
Nella realtà quotidiana ritroviamo tanti tipi di regole (di eleganza, di oratoria, di costume, ecc.) e fra queste vi sono anche quelle "giuridiche".
Ma cos'è la REGOLA GIURIDICA? Consultando un dizionario, troveremmo la definizione *"è la formula che indica o prescrive ciò che deve essere fatto in un caso determinato"*, ma questa definizione non arriva a soddisfarci in quanto troppo generica (vale per ogni tipo di regola, anche per una regola grammaticale), ed in quanto valevole anche per i "comandi", differenti dalle regole perché limitati a singoli casi e a singole persone. Ne deriva che bisogna andare più a fondo.

Una regola fa pur sempre parte di un linguaggio, di cui esistono 3 tipi (secondo Austin):

- **aletico (della verità)**: si basa su affermazioni semplici che dicono se una cosa è vera oppure no, se esiste oppure no, ecc. ("questa è un'auto", "Giorgio ha comprato un orologio", ecc.), sicché si tratta solo di stabilire se sono vere o false;
- **valutativo (giudizi di valore)**: si basa su affermazioni che contengono un giudizio di apprezzamento o di valore, una valutazione (es. "questo quadro è bello"), sicché si tratta solo di stabilire se sono oggettive o soggettive, generali o personali;
- **deontico (ciò che si deve fare)**: si basa su affermazioni che stabiliscono ciò che deve o non deve essere fatto, sicché si tratta di stabilire se siano fondate o infondate, cioè se dipendono da ragioni condivisibili oppure dall'arbitrio di chi li enuncia.

Questi tre tipi di linguaggio sono spesso collegati tra loro, ad es. il valutativo presuppone spesso l'aletico → si afferma se qualcosa esiste oppure no dopodichè si da un giudizio o valutazione; Uguale con il linguaggio deontico che presuppone il valutativo → io stabilisco cosa si deve fare o non si deve fare secondo quel valore che io ritengo più giusto. Solo l'aletico non presuppone altri linguaggi concatenati.

Orbene, è chiaro che la regola giuridica utilizza il linguaggio DEONTICO. Le affermazioni o proposizioni DEONTICHE si dividono in:
NON VINCOLANTI (consigli, invocazioni, ecc.) e VINCOLANTI (prescrizioni che il destinatario deve seguire).
Queste ultime a loro volta si dividono in:

1. **direttive:** sono prescrizioni "generali e deboli", perché rivolte a tutti o a intere categorie di persone, però vengono applicate secondo il giudizio dei destinatari che possono anche discostarsene (es. le prescrizioni estetiche, economiche, politiche)
2. **comandi:** sono prescrizioni "particolari e forti", perché rivolti a singoli soggetti che però non possono discostarsene (es. un comando militare)
3. **regole:** sono prescrizioni "generali e forti", perché rivolte a tutti e non si può discostarsene (es. non rubare, non uccidere).

È chiaro che le regole giuridiche si collocano in quest'ultima categoria. È però da precisare che in questa categoria rientrano anche altri tipi di regole, fra cui quelle morali e quelle "delinquenziali". Vediamo la differenza tra queste e le regole giuridiche: per regole "delinquenziali" intendiamo non l'ordine che il bandito impartisce alla sua vittima ("o la borsa o la vita", che è appunto un ordine (io-tu), ma quelle prescrizioni generali che un gruppo impone ad un altro gruppo (es. le regole estorsive che un'associazione a delinquere o racket impone ai commercianti di una città); è chiaro che anche questo tipo di regole hanno una struttura simile a quella delle regole giuridiche (generali e cogenti), ma vi è differenza.

Alcuni sostengono che la differenza stia nel fatto che nulla autorizza l'organizzazione delinquenziale a pretendere determinate cose o comportamenti, ma ciò non è sufficiente in quanto anche l'ordine impartito dallo Stato si basa sulla potenza.

Sicché tale differenza va ricercata altrove e ritorniamo così al linguaggio: vi sono 2 verbi che designano la prescrizione vincolante e sono "costringere" e "obbligare"; **ebbene si dice del bandito che costringa ma non obblighi**: quindi sia costrizione che obbligo vincolano, ma la prima in base alla forza, alla potenza, e finchè questa venga temuta, il secondo invece perché si è convinti di doverlo rispettare. **La costrizione si avvale del timore, l'obbligo della ragione e della convinzione.**
Quindi, la regola delinquenziale sarà pur "generalizzabile", ma NON "universalizzabile".

Ma come si fa a determinare l'obbligatorietà di una regola?
Una regola è obbligatoria in quanto conforme ad un valore (es. è obbligatorio fare ciò che è bene, ciò che è giusto, ecc.), quindi quella regola che è conforme al bene e alla giustizia, invece le regole delinquenziali sono conformi al disvalore.
Quindi la GIUSTIZIA è il criterio discriminante fra regola delinquenziale e regola giuridica.
In effetti, la GIUSTIZIA è un valore universalmente riconosciuto, sicché le sue regole risultano obbligatorie ma non costrittive e saranno cioè regole giuridiche.

Esaminiamo come opera la giustizia in relazione ai tipi di rapporti umani che stabilisce.
Sotto questo profilo, si può dire che tutte le forme di coesistenza sono raggruppabili in 3 categorie diverse di relazioni: interpersonali (amicizia, famiglia), societarie (o politiche) e universali (gioco, diritto, carità). Del pari si è soliti dire che la giustizia è: "rendere a ciascuno il suo e non offendere l'altro" e quindi possiamo distinguere la giustizia in INDIVIDUALE, SOCIALE e UNIVERSALE.
Esaminiamo i diversi tipi di giustizia.

A) LA GIUSTIZIA INDIVIDUALE
Per giustizia individuale si intende la giustizia che intercorre fra individui, sicché è meglio dire "intersoggettività". Essa riguarda i rapporti diretti fra soggetto e soggetto (o ente giuridico tipo una società che acquista da un venditore o altra società), rapporti che possono essere:
a) di scambio
b) di opera
c) di offesa e riparazione.

Vi è sempre un contraccambio bilaterale, basato sul criterio della EQUIVALENZA. Essa presuppone ovviamente una PARITA' di fondo fra i soggetti del rapporto: se non siamo pari, non contrattiamo uno scambio, non paghiamo l'operae io mi prendo la cosa con la forza, non cito in giudizio chi mi ha offeso ma lo punisco con la mia forza, ecc. Quindi questa giustizia "individuale" si basa sulla parità dei soggetti, ma ha dei limiti:

1. essa si stabilisce solo fra i soggetti del rapporto, che possono di comune accordo anche danneggiare un terzo o la stessa società (2 ladri decidono di spartire equamente fra loro la refurtiva);
2. la parità esiste all'inizio ma non è detto che permanga sino alla fine, sicché dall'accordo può derivare una disparità tra le parti tipo nel passato lavoratori e industriali.

È evidente quindi che la giustizia interindividuale va bene per regolamentare situazioni amicali, familiari, ludiche, economiche, ma non altre.

B) LA GIUSTIZIA SOCIALE (o meglio SOCIETARIA)
Visti i limiti della giustizia individuale caratterizzata da una situazione di inferiorità e spesso miseria dei lavoratori è nata nella fine dell'800 la giustizia sociale.
L'espressione è generica, in quanto la giustizia è sempre "sociale", anche quella intersoggettiva; occorre quindi addivenire ad una definizione più specifica e qualificante: si può dire che la giustizia sociale è quella che regola i rapporti di una "società", quindi meglio definibile come la GIUSTIZIA SOCIETARIA.
Da ciò è subito desumibile la sua differenza dalla giustizia intersoggettiva: quest'ultima è di tipo "orizzontale-diretto" (perché mette in rapporto due soggetti di pari posizione), mentre la societaria può essere o di tipo "verticale-diretto" (relazione fra i singoli e la società o Stato) o di tipo "orizzontale indiretto"

(mette in rapporto fra loro individui alla pari, però indirettamente attraverso la mediazione di un ente come lo Stato).

Poiché in ogni caso la società è superiore alle due parti, si può dire che la giustizia societaria sia "GERARCHICA e INEGUALITARIA", basata quindi non sulla parità ma sulla PROPORZIONALITA', per cui le parti si collocano in misura fra loro diversa in proporzione alla loro posizione.

La PROPORZIONALITA' si articola e si basa secondo 3 criteri:

1. delle ricompense secondo i meriti: il soggetto viene ricompensato in proporzione ai suoi meriti, il che dà luogo ad una disparità di trattamento che però risulta giusta (ammesso e non concesso che di fatto la proporzione attuata dallo Stato o da chi per lui sia giusta).
2. degli oneri secondo le capacità: ad es. il contribuente paga le tasse in base ai suoi guadagni e non in maniera paritaria, sicché è vero che pagano tutti (rapporto "verticale-diretto"), ma paga di più chi ha di più e magari avendo vantaggi minori (rapporto "orizzontale-indiretto"); il che dà luogo non solo a parità fra i contribuenti ma anche a disparità che però risulta giusto
3. delle posizioni secondo la rilevanza: più che i singoli individui, riguarda i gruppi-base nei quali la società si articola: in una società a base parentale i padri sono in una posizione predominante, così come i militari lo sono in una società militarizzata o i mercanti in una società mercantile. Fra questi gruppi vi sarà quindi una disparità di trattamento fondata sulla loro diversa rilevanza.

Tutti questi criteri possono essere ricondotti ad un unico principio che è quello della FUNZIONALITA', in base al quale si può stabilire una "giusta disparità di trattamento"; Come diceva Platone "la Repubblica ha il compito di stabilire l'equa disparità di trattamento in base alle classi e la funzione di queste".

Tuttavia, poiché la funzionalità delle parti sociali è variabile nel tempo e nello spazio, anche la concreta disparità di trattamento non è mai definitiva.
In ogni caso però oggetto e fine fondamentale della giustizia societaria è il perseguimento del BENE COMUNE.

Anche la giustizia sociale ha dei LIMITI:

- **la "chiusura" e "non universalizzabilità":** la giustizia sociale può arrivare a disconoscere la parità ontologica (esistenziale) fra gli individui in nome del bene comune e può distinguersi dal diritto in senso generale e universale: proprio in nome di una "purezza della razza" si possono accettare razzismi e classismi e giustificare anche il sacrificio dell'innocente in nome del bene della società (si pensi all'aborto volontario, per il quale in nome del bene sociale di evitarne la clandestinità, si arriva ad accettare la morte del feto innocente: posizione chiaramente antiabortista)
- **la tendenza ad attribuire una posizione di subordinazione** a coloro che, per vari motivi, non sono in condizione di contribuire allo sviluppo sociale (vecchi, malati, ecc.), soggetti deboli che rischiano di essere considerati dei pesi.

C) LA GIUSTIZIA UNIVERSALE

Quindi la giustizia intersoggettiva non tiene conto degli effetti che il rapporto giusto tra due soggetti può provocare sui terzi e sulla società, mentre la giustizia societaria non tiene conto della parità dei soggetti sia all'interno (nei riguardi dei deboli) sia all'esterno (nei riguardi degli estranei).
Sono pertanto giustizie di relazioni particolari e non universali, in quanto non prendono in considerazione l'esistenza dei terzi.

Vi è però un'altra forma di giustizia di tipo "UNIVERSALE" o "TOTALE": è sostanzialmente quella che si basa solo su REGOLE "GIUSTE", cioè quelle regole che prevedono pochissime eccezioni.
E' illusorio che esistano regole così perfette da non tollerare la minima eccezione, ma è anche vero che più una regola ammette delle eccezioni, più essa si avvicina ad essere una regola ingiusta.
La regola "giusta" si basa sempre su un principio fondamentale, il c.d. "PRINCIPIO PERSONA": ogni individuo ha diritto ad essere riconosciuto come tale, alla pari degli altri (sicché non è accettabile ogni forma di razzismo, schiavitù, ecc.) proprio perché il diritto nasce per tutelare l'Uomo e la logica dell'essere.

Ovviamente è vero che gli individui sono tutti diversi fra loro, quindi accanto alla uguaglianza di tutti in base al principio persona, vi è anche una diversità (e non disuguaglianza) esistenziale che però deve essere rispettata. Il principio persona si sostanzia nella regola base: "a ciascuno il suo senza arrecare danno a nessuno", dove abbiamo CIASCUNO, NESSUNO, SUO che rappresentano il combinarsi, nella giustizia, della universalità e della particolarità, ossia dell'uguaglianza e della diversità. Infatti, l'attribuire a ciascuno il suo, il non recare il danno a nessuno non comportano nessuna esclusione, quindi uguaglianza onotologica. **Cotta vede i diritti dell'Uomo come universali e preminenti rispetto a quelli del cittadino che sono particolari.**

CARATTERISTICHE della "giustizia universale" o "giustizia prima" o "giustizia ontoesistenziale":

1. **uguaglianza ontologica**: non potrebbe esservi giustizia se gli individui non si riconoscessero uguali fra loro. La violenza, la tortura sono ingiuste non solo perché provocano sofferenza ma soprattutto perché trasformano la vittima in una cosa; quindi ogni norma e azione che vìola l'uguaglianza ontologica è ingiusta
2. **simmetria** (o "reciprocabilità biunivoca"): se tutti gli uomini sono uguali, ne deriva che la libertà che io rivendico per me, devo riconoscerla a chiunque altro si trovi nella mia stessa posizione. Se viene meno questa sorta di "reciprocabilità", la mia pretesa diventa solo un tentativo di dominare gli altri e scade da "diritto" a "pretesa"
3. **corrispondenza fra diritti e doveri**: ciò che ha titolo per essere riconosciuto come diritto per un soggetto implica un corrispondente dovere dell'altro: un diritto che altri avrebbero la libertà di non rispettare non sarebbe un diritto ma una semplice pretesa. Insomma, si ha diritto quando non vi è libertà di sottrarsi ad esso o di opporvisi, ma vi è il dovere di rispettarlo
4. **adeguatezza**: le azioni reciproche dei due soggetti devono essere adeguate fra loro; ad es. l'usura non è adeguata perché non vi è proporzione fra somma prestata e interesse richiesto, l'ergastolo per un furto non è adeguato perché non vi è proporzione fra gravità dell'illecito e pena inflitta. Occorre, quindi, una proporzionalità sei si vuol far rispettare una regola
5. **rispetto universale del giusto**: se ad es. uno studente ottiene per i suoi meriti un voto più alto è anche giusto che tutti rispettino tale valutazione (non molto chiaro)
6. **imparzialità del giudizio:** la giustizia esige sempre un giudizio disinteressato ed imparziale; ciò comporta ovviamente che vi sia un terzo (giudice, arbitro) che non sia coinvolto nella questione da decidere ("nemo iudex in causa propria"), che siano ascoltate le ragioni di tutte le parti ("audietur et altera pars") e poi che siano raccolte prove oggettive dei fatti.

In questo tipo di giustizia, si trova tutto ciò che permette alla regola di evitare eccezioni; essa si basa quindi sulla REGOLA IN SÈ, che si distingue sia dalle prescrizioni particolari (quindi non universali) e sia dalle regole basate imposte con la forza e perciò prive di obbligatorietà, in quanto non legittimate dall'accettazione dell'altro. NELLA GIUSTIZIA ONTOESISTENZIALE si trova pertanto ciò che permette alla regola (legge) di essere priva di eccezioni e quindi giusta. **Intesa in questo senso, Per Cotta la giustizia costituisce il trascendentale della regola**, (=non si può parlare di norma giuridica a prescindere dalla giustizia; trascendentale non va confuso con trascendente in quanto trascendente significa ciò che sta al di la, ciò che non si conosce invece trascendentale è ciò che è aldiquà, un apriori, non ha bisogno di essere di dimostrato ma lo si da per scontato e in funzione di questa distinzione possiamo dire che Cotta vuol dire che non si può parlare di norma giuridica a prescindere della giustizia).

S. Agostino dice che la legge coincide con la giustizia è impossibile che esista legge che prescinda dalla giustizia.

Per Aristotele la giustizia è: distributiva (ad ognuno il suo), simmetrica (uguaglianza), Sociale (garantisce i diritti ai consociati) e universale (è pubblica, di tutti: "se una norma viene resa pubblica vuol dire che non c'è nulla da nascondere).

Platone include la giustizia nelle virtù cardinali →Distinzione delle virtù cardinali e teologali:

Quattro virtù hanno funzione di «cardine». Per questo sono dette « cardinali »; Sono: *la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza.*

Tre virtù sono teologali, si riferiscono a Dio e dispongono i cristiani a vivere in relazione col divino: *la fede, la speranza e la carità.*

CAPITOLO XI: DALLA GIUSTIFICAZIONE DELLE NORME AL DIRITTO NATURALE

Abbiamo visto che la giustizia è il fondamento su cui poggia la regola giuridica e la sua obbligatorietà.
Perché le regole giuridiche sono sentite come "OBBLIGATORIE" (convinzione e non costrizione)?
Perché esse si basano sul principio detto della "GIUSTIFICAZIONE".
Approfondiamo questo principio.
Una norma giuridica prevede sempre un "dover-essere" o un "dover-fare": una norma che non si basasse sulla obbligatorietà non sarebbe mai una norma giuridica ma solo una generica norma prescrittiva, che i destinatari sarebbero liberi anche di non attuare.
Ovviamente poi, la semplice promulgazione di una norma non è sufficiente a stabilirne l'obbligatorietà e neppure basta che sia previsto la coercizione contro i trasgressori (a tale forza se ne potrebbe opporre un'altra più potente e comunque non è possibile ricorrere continuamente alla forza) e neppure è sufficiente l'autorità dell'ente che emana.

In realtà (come già detto) la vera obbligatorietà della norma giuridica non si basa soltanto sul suo dettato esplicito, sulla forza e sull'autorità, ma trova il suo vero fondamento nella GIUSTIFICAZIONE.
La giustificazione è costituita in 3 parti:

1. **oggetto**: è la prescrizione prevista dalla norma
2. **scopo:** nessuna giustificazione, per quanto solida, è in grado di impedire ogni trasgressione; quindi lo scopo della giustificazione è quello di dimostrare che il principio previsto dalla prescrizione normativa è ragionevole, perciò "non rifiutabile"
3. **requisiti:**
   a) la reale possibilità di tenere il comportamento prescritto (la prescrizione di un comportamento impossibile è ingiustificabile);
   b) la prescrizione deve essere "razionale" ovvero non deve basarsi su presupposti non giustificabili;
   c) deve valere per tutti gli interessati;
   d) il comportamento prescritto deve essere approvabile da chiunque (spesso l'approvabilità viene letta "nel senso dell'ideologia dominante storica").

Per Cotta quindi, le regole giuridiche sono sentite come obbligatorie perché si basano su un principio della giustificazione basato sulla funzionalità coesistenziale della prescrizione.
Le teorie attuali come Kelsen non considerano l'obbligazione alle norme giuridiche come legati alla giustificazione ma alla validità: una norma è obbligatoria se valida ed è valida se inserita nell'ordinamento.
Secondo Kelsen, la validità VIENE ACCERTATA mediante un controllo di coerenza formale e contenutistica con le altre norme superiori nell'ordine gerarchico delle norme fino ad arrivare ad una presupposta norma fondamentale. Questa groundnorm però si basa su un presupposto non giustificato, tutte le norme dipendono dalla groundnorm che di fatto non è giustificato.

Ciò premesso, cerchiamo finalmente di stabilire qual è il tipo di giustificazione che meglio soddisfa questi elementi: secondo Cotta è "FUNZIONALITA' COESISTENZIALE DELLA PRESCRIZIONE".
Pensiamo ad es. alla prescrizione "i cittadini devono obbedire alle leggi dello Stato": è chiaro che questa norma è giusta, cioè è giustificata perché è il presupposto indispensabile senza cui non potrebbe sussistere "la coesistenza delle persone nello Stato".
Quindi, in sostanza, possiamo dire che la funzionalità di una norma che è indispensabile per consentire la coesistenza degli uomini in una data struttura ne giustifica la relativa obbligatorietà (poiché il comportamento X è indispensabile per la coesistenza universale, si deve compiere X).
Poiché l'obbligatorietà è ciò che rende giuridica la norma, questa è tale quando il suo contenuto prescrittivo è giustificato o in relazione ad un contesto, particolare o universale che sia.

Passiamo ora ad esaminare la questione dell'ESISTENZA del DIRITTO NATURALE.
E' noto che le teorie "positivistiche" del diritto negano l'esistenza del diritto naturale, inteso come una sorta di diritto ideale, che non può esistere in concreto.

E' agevole però contestare a tale tesi che la "natura" cui si fa riferimento quando si parla di diritto naturale non è certo quella intesa in senso fisico-materiale, bensì la natura specifica dell'uomo, quella ontologica dell'essere umano.
Ma, superata facilmente tale prima obiezione, si deve rilevare che il "giuspositivismo" (che esclude il diritto naturale) fonda più approfonditamente la sua critica al diritto naturale su altri due concreti difetti dai quali sarebbe affetto: a) la sua mancanza di una fonte reale; b) la sua "non giustiziabilità", nel senso che questo diritto non può essere applicato in un giudizio.
Partendo da quest'ultimo rilievo, possiamo però notare come questo sia contraddetto dalla realtà: è vero che in genere gli ordinamenti giuridici ammettono solo norme positive, però ammettono ad es. "il giudizio secondo equità", e il che dimostra che accanto alle norme di diritto positivo, gli ordinamenti ammettono anche l'applicazione di principi di diritto comune ed equitativo.
Quanto alla prima obiezione, essa parte dalla erronea premessa che il diritto naturale sarebbe una sorta di diritto che trova la sua fonte in una ideale Natura, mentre è vero invece che questo diritto nasce pur sempre dall'uomo: sono gli uomini che "inventano" (da in-venio=trovare) questo diritto naturale, che è giustificabile in quanto anch'esso funzionale alla coesistenza degli esseri umani.
Sotto tale punto di vista, non vi sarebbe opposizione tra diritto naturale e diritto positivo che invece, trovando entrambi la loro giustificazione nella finalità di assicurare la coesistenza degli uomini, **fanno entrambi parte del diritto vigente → DIRITTO NATURALE VIGENTE (naturalismo e positivismo).**

Altra questione: si è soliti ritenere che il diritto naturale sia un sistema di norme immutabile.
In realtà nemmeno questa tesi è del tutto esatta: esiste un diritto naturale che stabilisce regole universali ed assolute (ad es. "il rispetto dell'innocente"), quindi immutabili, ma anche regole suscettibili di cambiamenti (ad es. l'obbligo di obbedire a determinate leggi dello Stato).
In ogni caso solo il diritto naturale universale ed immutabile è qualificabile come diritto naturale ASSOLUTO.

A conclusione delle considerazioni precedenti, giungiamo ad inquadrare il concetto della LEGALITA'.
In passato, la legalità presupponeva che la legge fosse intrinsecamente giusta, quindi la legalità equivaleva al comportamento giusto; invece nel pensiero moderno, la legalità consiste nel semplice rispetto delle leggi poste dall'ordinamento, indipendentemente dal loro contenuto giusto o ingiusto.
Se viene intesa in questo senso, che possiamo definire "FORMALE", allora la legalità è disgiunta dalla giustizia; ma in tal caso, una norma disgiunta dalla giustizia non sarebbe più una norma ma una semplice prescrizione, basata solo sulla forza e sul timore.
Invece, la vera legalità è quella che si basa sulla GIUSTIZIA, e quindi su norme "obbligatorie", assumendo così il concetto di "valore" che consente la coesistenzialità umana.
Per Kelsen una norma è valida se inserita nell'ordinamento giuridico, per Cotta una norma è valida se giusta quindi se conforme al valore di giustizia ontoesistenziale.

CAPITOLO XII: POSITIVITÀ E VIGENZA DEL DIRITTO NATURALE

Lo studio del diritto naturale merita un ulteriore approfondimento, in quanto attualmente si sono sviluppati altri orientamenti "antigiusnaturalistici", fra cui lo "STORICISTICO" e il "POSITIVISTICO" e il "LOGISTICO".

ORIENTAMENTO STORICISTICO E SUA CRITICA.

Secondo i sostenitori di questa teoria, il diritto non sarebbe "naturale" ma solo "storico": in sostanza si sostiene che non è pensabile un diritto naturale in quanto il diritto nasce e si modifica a seconda dei periodi storici ed è una variabile da questi dipendente.
Cominciamo allora con l'osservare come il diritto non appartenga ad una o a diverse culture, bensì si trova in tutte le forme di coesistenza dell'uomo; ne consegue che esso è un FENOMENO TRANS-STORICO e TRANS-CULTURALE, dotato quindi di transitività spaziale e temporale (evoluzione, variazione), così come si trovano sempre le figure ad esso collegate del legislatore, del giudice, dell'esecutore delle norme.
E' vero che se il diritto è trans-storico, le norme che lo compongono sono soggette a continui cambiamenti a seconda dei vari periodi storici, ma in ogni caso non può accettarsi la concezione storicistica perché quando

parliamo di diritto naturale, non ci riferiamo ai "contenuti" del diritto, cioè le varie norme che cambiano, ma alla sua natura di base che è sempre la medesima.

Riepilogando. Il fenomeno giuridico è "naturale" in quanto insito nella natura umana e contenenti leggi conformi all'uomo sempre, anche se è ovvio che i contenuti nei quali tale giuridicità si concretizza volta per volta (principi, norme, istituti giuridici) non lo sono.

ORIENTAMENTO POSITIVISTICO E SUA CRITICA.

Secondo i sostenitori di questa teoria, il diritto naturale non può esistere perché "se è naturale, non è diritto e se è diritto, non è naturale". Inoltre, il diritto naturale esiste solo come "diritto ideale" perché conforme a determinati valori ideali e perciò non è un diritto vigente, positivo scritto.
In sostanza, il diritto naturale avrebbe, al più, una funzione propositiva (che contiene una proposta) ma non positiva.
Se ci dovessimo fermare a questo stadio ideale, propositivo ma non positivo, il diritto non sarebbe effettivamente ancora un diritto "reale", cioè vigente, perché manca della categoria del "dover-essere", tipica del diritto positivo.

Abbiamo quindi indicato un grosso ostacolo (riassumiamo): il diritto naturale prevede un "essere" (in tedesco SEIN), mentre il diritto positivo prevede un "dover-essere" (in tedesco SOLLEN): secondo la c.d. "legge di Hume", non è possibile passare logicamente da una proposizione aletica a una deontica ovvero da una proposizione di essere ad una di dover essere (dal SEIN al SOLLEN).
In realtà questa tesi è superabile: il SOLLEN presuppone pur sempre un giudizio di valore; non può nascere l'obbligo giuridico (il SOLLEN) se alla sua base non c'è la consapevolezza del valore di quell'obbligo, cioè la consapevolezza che si deve fare così perché è bene, è giusto che si faccia così. Ma chi stabilisce cosa è buono e giusto? E' evidente che è pur sempre l'uomo, l'essere, il SEIN: ecco quindi dimostrato che all'origine del SOLLEN vi è sempre il SEIN dell'ente-uomo.
Allora, se ogni SOLLEN presuppone un ineliminabile referente antropologico, un SEIN che è proprio dell'uomo, ecco che si ripropone il dubbio: il diritto può considerarsi solo e semplicemente una "norma tecnica" (come dicono gli stessi giuspositivisti)?
In realtà: se è vero che all'origine del Sollen vi è un Sein, che quindi il diritto positivo poggia sull'uomo, allora è vero che il diritto senza un referente umano è un "non-senso"; allora, se il diritto si basa sull'uomo, cioè sulla natura umana, è evidente che il diritto può qualificarsi come "naturale" e dunque non è vero che non ha il dover essere (se a allora b).

Ciò detto, è vero che il diritto positivo presenta le caratteristiche che sono proprie dell'uomo e quindi un implicito diritto naturale?

Verifichiamolo focalizzandoci sulla prima tipica caratteristica dell'uomo ovvero la sua "relazionalità":
l'uomo non è mai in condizione di vivere da solo, ma anche il diritto è "relazionale" perché se non esiste oltre all'io un altro io, non potrebbe sorgere l'esistenza delle regole, cioè il "dover-essere".
E in effetti la relazionalità è alla base dell'intera normativa che regolamenta tutte le relazioni fra uomini e Stati.
Dunque la relazionalità dell'uomo è il presupposto antropologico del diritto.
Vi è anche una seconda caratteristica dell'uomo, che ritroviamo anche nel diritto: nell'uomo vi è sempre unità fra interno ed esterno (l'interno è la psiche, l'esterno è la sua volontà e la conseguente azione).
Quindi, alla base del Sein (cioè dell'essere umano) vi è lo stretto collegamento, la "transitività" stretta fra interno ed esterno dell'uomo.
Ma la consapevolezza di questo collegamento la ritroviamo anche nel diritto: si veda ad es. il diritto privato che bada alla capacità di intendere e di volere del contraente, il diritto penale che bada alla imputabilità dell'imputato e all'elemento psicologico del reato.

Altra caratteristica dell'uomo è la temporaneità, è finito, giunge al termine e così il diritto nasce, vive e muore (secondo la triade circolare del essere, fare e avere) e a volte il tempo diviene diritto (una legge sulle ore di lavoro che prima era 12h adesso 7h massimo) e a volte il diritto che diviene tempo (il testamento del de cuius rappresenta la volontà che si fa legge).

Allora ecco che anche sotto tale punto di vista si è dimostrato lo stretto collegamento che vi è fra il diritto e l'uomo, fra il Sollen (il dover-essere) e il Sein (l'essere).
E se così è, risulta giusta l'asserzione secondo cui il diritto naturale esiste in quanto si ricollega alla natura dell'uomo. Sicché possiamo equiparare il concetto di DIRITTO POSITIVO al concetto di DIRITTO NATURALE VIGENTE ovvero costituito da diritto naturale.

CAPITOLO XIII: LA TEMPORALITÀ DEL DIRITTO

Occorre a questo punto esaminare la DIMENSIONE TEMPORALE DEL fenomeno giuridico.
Nessuno può dubitare della temporalità dell'uomo (che va dalla nascita alla morte); anche il diritto, che è un fatto umano, è contrassegnato dalla temporalità: basti pensare alla validità delle norme, validità che a seconda che si rapporti ai soggetti, al territorio, al tempo, ha un ambito personale, spaziale e, appunto, temporale.
Bisogna però precisare che la scienza giuridica solitamente si limita a constatare l'esistenza del rapporto fra tempo e norme giuridiche, ma non affronta il problema del "perché" questi dati giuridici abbiano una dimensione temporale.

A prima vista, il rapporto diritto-tempo vede questi 2 termini come una sorta di potenze rivali: il tempo consuma tutto e quindi anche il diritto è soggetto a tale opera distruttiva.

Ma questa tesi è vera solo parzialmente: quando si esamina questo problema, in genere ci si ferma ad un primo livello senza procedere oltre, ma in realtà vi è un secondo livello.
Esaminiamo questi 2 LIVELLI:

1. **PRIMO LIVELLO**. Effettivamente a questo livello, il rapporto indicato si basa su una contrapposizione netta, che può sfociare in due tesi opposte:
   1) il tempo domina il diritto: lo fa nascere e lo fa sparire (si pensi alla prescrizione, all'usucapione, alla consuetudine, ecc.);
   2) il diritto domina il tempo: sia perché gli impone le proprie misure, che sono diverse da quelle "dell'orologio" (scadenza dei termini, ecc.), sia perché il prima e il dopo assumono rilevanze diverse a seconda del tipo di statuizione (il precedente giudiziario si impone alle decisioni future, la legge successiva prevale su quella anteriore, ecc.) oppure creano situazioni giuridiche che rimangono inalterate nel tempo (si pensi alla permanenza dei diritti dopo la morte per successione agli eredi).
2. **SECONDO LIVELLO**. Questa prima rappresentazione simbolica che evidenzia l'opposizione fra tempo e diritto non spiega quale dei due risulti "vittorioso". Procedendo oltre, si finisce invece col rappresentare il rapporto diritto-tempo come un processo di CIRCOLARITA' DIALETTICA (l'uomo se è vuole fare se vuole fare vuole avere) in un inseguimento circolare: è vero che il tempo erode progressivamente norme e istituzioni, ma è anche vero che quando quella data norma scompare sotto l'azione del tempo, ecco sorgerne una nuova a contrastare il dominio del tempo, quindi il diritto continua ad esserci e il dominio di uno dei due sull'altro non è mai definitivo.

Il diritto non può mai scomparire finché permane la vita umana e sussiste, quindi, una VERA CIRCOLARITA' DIALETTICA fra i due.

Stabiliamo ora in che maniera e con quali effetti il diritto si inserisce nel rapporto uomo-tempo. Si è visto che il diritto è una relazione coesistenziale, relazione che fa parte della vita e perciò ha sempre una sua DURATA. Il tempo nel diritto è un "TEMPO-DURATA", perché i vari atti sono uniti fra loro dalla "intenzione" dell'uomo che vuole raggiungere un risultato: una norma che valutiamo ora è il presente, ma presuppone la conoscenza della sua passata creazione e genera in noi l'aspettativa dei suoi effetti futuri; una sentenza emessa nel presente si riporta al precedente illecito e al futuro della sua esecuzione.

Quindi il tempo nel diritto non è una semplice "successione di momenti", ma una "DURATA".
Questa temporalità del diritto è tipica della sensazione che ha l'uomo della sua temporalità: l'io per comprendere la propria durata non può mai risolversi nell'istante, ed ha bisogno della MEMORIA: se non ho la memoria di essere già stato, non potrei affermare che ora sono né prevedere che sarò nel futuro.

Però la memoria ha un grave limite: essa è discontinua, non può essere sempre attiva, altrimenti si vivrebbe in uno stato di concentrazione continua, cadendo nell'alienazione.
Quindi la continuità della memoria si ha a livello inconscio, ma essa è discontinua a livello conscio:

L'incontro con l'altro da sé riduce la discontinuità della memoria (facendola emergere), ma non la elimina del tutto, perché anche tali incontri sono discontinui. Orbene si è visto che la regola (su cui si fonda la relazione giuridica) avverte il tempo (passato, presente e futuro), poiché la regola "è stata posta", ora "è vigente" e riguarda il "sarà del mio comportamento".
Quindi, anche la regola implica "DURATA" (e in ciò si distingue dal comando), e la mia volontà, che si conforma alla regola, acquista anch'essa durata e mantiene durata anche per il mio "io" e poiché la regola giuridica mette in relazione il mio "io" con quello degli altri, essa mi impedisce di isolarmi e mi dà coscienza della coesistenzialità aiutandomi ad avere memoria di quel che sono in maniera più continua.
Se l'uomo è sintesi di tempo ed eternità, di tale sintesi è partecipe anche il diritto.
Il diritto naturale perenne non muta, quello positivo è soggetto al tempo, come le due parti dell'Uomo.

MORALITÀ DEL DIRITTO:
Importante la differenza tra etica e morale: **l'etica mi mette in relazione con l'altro; la morale mi mette in relazione con me stesso.** Legge morale= Non è scoprire cosa è bene o male in forza della volontà del soggetto (di quel che il soggetto vuole) MA scoprire ciò che è male in se e ciò che è bene in se, al fine di comportarsi secondo quelle regole che possono valere per tutti *"Agisci in modo da considerare sempre la massima della tua volontà come legge universale".*
→ **CHIARIRE QUESTO CONCETTO**

se la morale significa trovare dentro se il giusto o sbagliato avendo come riferimento l'universale, e cotta dice che nella carità c'è maggiore moralità che vuol dire? Cotta vole dire che la carità è quella forma esistenziale che permette di scoprire in ognuno di noi cosa è universalmente giusto o sbagliato?

Cotta dice che esistono tante forme morali quante sono le forme coesistenizali: amicizia, politica, famiglia, gioco, diritto e carità. Tra tutte le morali delle forme coesistenziali che non sono solo 6, la morale per eccellenza è quella che si trova nella forma coesistenziale sguarnita di giuridicità. La carità è la morale delle morali, come la groundnorm di Kelsen o la groundvert di Incampo, è il vertice.
Si fa strada nell'epoca moderna la TESI della AMORALITA' DEL DIRITTO, che basa la sua obbligatorietà non sulla sua eticità o moralità ma sulla sua effettività, cioè sulla potenza della sua imposizione (Kelsen basa l'obbligatorietà della norma sulla sua effettività e validità, invece per Cotta, le regole giuridiche sono sentite come obbligatorie perché si basano su un principio della giustificazione basato sulla funzionalità coesistenziale della prescrizione).

L'amicizia personale stabilisce una morale estremamente limitata quanto ai soggetti, che sono solo due; risulta più ampia, la possibilità di estensione della relazione politica, ma neppure questa assume un'estensione universale, presupponendo una limitazione al numero dei soggetti, che sono solo quelli legati dallo stesso vincolo politico.

Il gioco si apre all'universale ma la coesistenzialità ludica ha dei limiti:
- La moralità è limitata alla "categoria dei giocatori" ed esclude comunque coloro che nella libera scelta non scelgono di giocare
- I giocatori inizialmente sono uniti su un piano orizzontale, ma la vittoria fa divenire i soggetti asimmetrici, con chi è vincitore e chi è perdente.

Il diritto e la carità, invece, corrispondono a questo criterio: la relazione giuridica supera anche i limiti dello Stato, poiché essa assume una dimensione universale nel riconoscere ad ogni uomo la sua qualità di persona; la carità è tale proprio perché si esercita nei confronti di chiunque senza limitazioni.

Ma quale delle due è al vertice supremo? il rapporto caritativo è un rapporto "asimmetrico", poiché chi vuole fare carità ha il dovere di amare ogni persona ma non il diritto di chiedere la reciprocità; invece il

rapporto giuridico è "simmetrico", poiché fra i suoi membri vi è corrispondenza reciproca di diritti e doveri (nel diritto nessuno ha solo diritti o solo doveri).

Quindi possiamo dire che la carità porta ad un'accoglienza totale dell'altro, di là dai suoi diritti o doveri, in un atteggiamento di dono e perdono, che va oltre la misura della giustizia, sicché il destinatario privilegiato della carità è l'estraneo, l'avversario: è proprio questa "oltre misura" della carità a segnare la sua SUPREMAZIA SULLE ALTRE FORME DELLA VITA MORALE.

CONFRONTI TRA INCAMPO E COTTA:

Il filo rosso tra i testi di Incampo e Cotta è quello della intersoggettività, coesistenza, conesserci, Mit-da-sein (con esserci), diritto visto come un sistema di valori fondato sulla condivisione (funzione del diritto, validità della norma, obbligatorietà=tendenza al valore, per COTTA la giustizia).

INCAMPO schiude un altro punto di vista circa le possibili connessioni tra diritto e morale. Il testo del professore Incampo si colloca in una di linea ideale prosecuzione con il testo di Cotta perché sia in Cotta che in Incampo il diritto positivo ha sempre un'innata vocazione etica e coesistenziale.
Il diritto positivo, per quanto positivo sia, sia per Incampo che per Cotta raffigura la natura dell'Uomo.
Quel che cambia tra Incampo e Cotta è il metodo di studio del diritto che in Incampo è un approccio LOGICO-ANALITICO e non FENOMENOLOGICO –ESISTENZIALE.
Un importante punto di contatto con Cotta emerge ancora quando c'è il riferimento alla filosofia Kantiana, e qui le due teorie di Incampo e di Kant hanno una comune prospettiva.
- Incampo muove da una prospettiva Kelseniana e di filosofia del linguaggio normativo per giungere ad una visione del fenomeno giuridico che abbia le caratteristiche della universalità e della eticità.
- L'obiettivo che muove Incampo è quello di allargare le maglie del concetto di validità della norma Kelseniana e del formalismo e positivismo per farvi entrare anche un concetto di valutazione etica circa le norme dell'ordinamento.

Per Kelsen la legge non viene scoperta dal legislatore perché esistente già in natura ma viene creata "la norma è frutto di un volere" e quindi Kelsen dirà che la legge è creata dall'autorità e non dalla verità e ciò è sbagliato perché non si può ridurre il diritto, frutto umano, a qualcosa di formale.
La norma giuridica per Kelsen è costituita da una struttura piramidale dove al vertice c'è la groundnorm che è formata da una sua validità presupposta e non posta come le normali norme ordinarie che attingono le loro validità dalle norme che le precedono ad infinito fino a quando il regresso all'infinito si pone la norma fondamentale - GROUNDNORM. La norma per Kelsen è valida se inserita in un ordinamento giuridico mentre l'ordinamento giuridico sarà valido se riprende la sua validità dalla norma fondamentale.

Incampo si muove da questa prospettiva Kelseniana inserendo il concetto di valore fondamentale, non c'è solo una Groundnorm ma GROUNDWERT ovvero il valore fondamentale. Questo valore fondamentale deriva dal principio trascendentale (Si da per scontato, aprirori) del valore puro del diritto (cioè la giustizia) presente in Cotta che dice che una norma è obbligatoria quando si basa sul principio della giustificazione basato sulla funzionalità coesistenziale della prescrizione (=coincidenza col valore fondamentale di giustizia. Giustizia che dice cotta è universale=universalmente condivisibile, rispetta l'ontologia dell'Uomo e costituisce il trascendentale della regola ovvero la giustizia che per Cotta è il trascendentale). Kant nella "pace perpetua" dice che la legge per essere giusta deve essere anche pubblicizzaible, noi nascondiamo un pensiero losco e non lo gridiamo in pubblico.
Allora l'ordinamento trova il suo fondamentale sia nella norma fondamentale che nel valore fondamentale.